



TEORÍA DE LA LEY

Apunte realizado en base al texto "Teoría de la Ley", del profesor Joel González Castillo, más textos complementarios de Francisco González Hoch (El derecho como ordenamiento) y Carlos Ducci Claro (Derecho Civil Parte General) Material en revisión.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la Teoría de la Ley tiene por objeto principal, como su nombre indica, todo lo relativo a la ley. Sin embargo, su objeto es algo más amplio. En general, se refiere al sistema de fuentes del derecho en nuestro ordenamiento jurídico, y a los principios más generales que rigen su configuración. Ahí radica la importancia del estudio atento de estas materias: su adecuada comprensión es necesaria para aprehender la estructura del derecho en general, y del derecho privado en particular.

Especial relevancia revisten el estudio de la estructura y principios del Código Civil, los efectos de la ley en el tiempo y en el espacio, la interpretación de la ley y las reglas generales de la costumbre como fuente del derecho.

Las normas que estudiaremos en este apunte se encuentran contenidas, fundamentalmente, en el Título Preliminar. Sin embargo, dado que el estudio de los principios que inspiran el Código Civil supone una referencia a todos los libros del Código, el estudio de la Teoría de la Ley requiere tener toda la legislación civil en su conjunto. Por otro lado, el estudio de los efectos de la ley en el tiempo implica un análisis de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes.

Lo anterior supone una dificultad, toda vez que el o la estudiante deberá tener en mente reglas propias de otras ramas del derecho civil para efectos de comprender a cabalidad la Teoría de la Ley. En ese sentido, nuestras recomendaciones son dos. Por un lado, es necesario estudiar siempre con el Código Civil en mano, y a ponerle especial atención a cada una de las reglas a las que haremos referencia, para poder captar desde ya el esquema general del derecho civil. Por otro lado, hacemos un llamado a la paciencia y al estudio atento por ahora, y a tener estos principios generales en mente mientras estudien las demás materias, para terminar de integrar y aprehender el derecho como un todo.

Índice

1. El derecho y el derecho civil	4
1.1 Definición de derecho	4
1.2 Derecho Civil	10
1.3 Estructura y contenido del Código Civil	12
1.4 Principios que inspiran el Código Civil	14
2. Las fuentes del derecho	25
2.1 Generalidades	25
3. La ley	27
3.1 Concepto	27
3.2 Características de la ley en cuanto a su contenido	27
3.3 Definición del Código Civil	27
3.4 Clasificación de las leyes	28
3.5 Autoridad de la ley	30
3.6 Efectos de la ley en cuanto al tiempo	31
3.6.1 Teorías para determinar si una ley es retroactiva	34
3.6.2 Ley sobre efecto retroactivo (LERL)	37
3.7 Efectos de la ley en cuanto a las personas	40
3.8 Efectos de la ley en cuanto al territorio	41
3.9 Interpretación de la ley	44
4. La costumbre	52
4.1 La costumbre de la fuente del derecho	52
4.2 Requisitos de la costumbre	52
4.3 Eficacia de la costumbre	53
4.4 Tipos de costumbre y valor	53
4.5 Prueba de la costumbre	58
4.6 La casación y la costumbre	59
5. La jurisprudencia	60
5.1 Alcance de la sentencia judicial	61
6. La doctrina	64
6.1 Antecedentes históricos	64
6.2 Valor normativo	65
6.3 Funciones en relación con el derecho vigente	65
7. Anexo: Clasificación de las fuentes del derecho	66

TEORÍA DE LA LEY

CAPÍTULO 1. EL DERECHO Y EL DERECHO CIVIL

1.1 DEFINICIÓN DE DERECHO

1. Derecho objetivo y derecho subjetivo.

Derecho objetivo: es el conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres en la sociedad, regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas normas.

De la definición transcrita se desprende que la finalidad del derecho objetivo es mantener el orden y la paz social, disciplinando, para lograr esta finalidad, las relaciones de los hombres que viven en sociedad, o sea, el Derecho establece las reglas conforme a las cuales deben desenvolverse las relaciones de los coasociados, no todas, sino las que las mismas normas del Derecho determinan. Las relaciones que el Derecho disciplina o regula se llaman relaciones jurídicas.

La relación jurídica puede ser definida como un vínculo jurídico entre dos o más personas, de la cual emanan derechos y obligaciones. Es importante notar que la relación jurídica no puede ser reducida al vínculo obligacional, pues existen otras relaciones jurídicas tales como la relación de parentesco, la de matrimonio, etc. El punto es que, aunque la relación jurídica no corresponda a un vínculo obligacional, de ella emanan derechos y obligaciones.

Derecho subjetivo: es el señorío o poder de obrar reconocido u otorgado por el Derecho objetivo a la voluntad de la persona para la satisfacción de los propios intereses jurídicamente protegidos.

Todo Derecho subjetivo encierra un interés jurídicamente protegido.

Por interés se entiende, en este caso, el provecho o la utilidad que para un sujeto tiene el gozar de algo material o inmaterial. También se dice que interés es la utilidad o provecho que para un sujeto tiene el disfrutar de una situación dada.

Al Derecho subjetivo corresponde siempre un deber o una obligación de otra u otras personas. Tal deber u obligación puede tener por objeto una acción o una abstención.

El Derecho objetivo y el subjetivo no son conceptos antitéticos, sino aspectos diversos de una misma esencia, pues el Derecho subjetivo existe gracias a que lo otorga o reconoce y protege el Derecho objetivo.

2. Caracteres particulares de las normas jurídicas.

Las personas que viven en sociedad no sólo están regidas, al realizar sus actos, por normas jurídicas, sino también por otras de muy diferente clase: morales, religiosas, de uso social (prácticas de cortesía, de etiqueta, de respeto a la dignidad ajena), etc. Necesario es entonces determinar los rasgos peculiares que distinguen a las normas jurídicas de todas las demás. Estos caracteres son:

1) Finalidad. El fin de las normas jurídicas es mantener el orden y la paz social. Este objetivo es el carácter más relevante del Derecho y bastaría para definirlo, pues no hay ningún otro sistema normativo que persiga como propio de su esfera dicha finalidad.

2) Imperatividad. Las normas jurídicas son imperativas porque expresan un orden, un mandato, y no un ruego, un consejo o una sugerencia. Se dirigen a los miembros de la comunidad, que están obligados a acatar el mandato por la conveniencia de hacerlo o por temor a las sanciones que, por lo general, trae la violación o desobediencia de la orden.

Si las normas jurídicas no fueran obligatorias y quedaran a merced de la sola voluntad de los individuos, sobrevendría el caos y la anarquía.

Hay normas que permiten ellas mismas dejar de lado su mandato (normas de orden privado); en esta hipótesis el mandato se reduce a los casos en que los particulares no descarten la aplicación de la norma. Es como si ésta dijera que si sus destinatarios no expresan algo distinto de lo establecido por ella, impera y obliga su mandato.

3) Heteronomía. Las normas jurídicas, con relación a los hombres a los cuales se dirigen, son heterónomas porque se siguen o adoptan no por propia voluntad de éstos, como las morales o religiosas, sino por imposición de una voluntad ajena exterior, la del creador de la norma.

Así, pues, las normas jurídicas son heterónomas en contraposición a las religiosas y morales, que son autónomas, porque los individuos las siguen o adoptan no por imposición de otro, sino por la propia voluntad, escuchando la voz de sus conciencias.

4) Alteridad o bilateralidad. La norma jurídica no es una regla de conducta para el individuo aisladamente considerado, no rige el comportamiento de la persona en sí mismo, sino en relación con el de los otros, sus semejantes. Este carácter se conoce con el nombre de bilateralidad, intersubjetividad, socialidad o alteridad, palabra esta última derivada del latín alter, que significa el otro, el no yo, y efectivamente no se dan para el hombre en soledad sino para sus relaciones con otros hombres, entre los cuales establecen derechos y deberes, al revés de las normas morales y las de uso social que sólo crean deberes.

5) Abstracción. El carácter abstracto es también un rasgo de las normas

jurídicas. No prevén ellas casos concretos, sino situaciones-tipo. No dicen las normas de derecho, por ejemplo que la deuda que tiene Primus con Secundus debe ser pagada, porque de lo contrario estará obligado a indemnizarle los perjuicios resultantes, sino que si un deudor no cumple exacta y oportunamente su obligación, estará en la necesidad de indemnizar los daños que de ello se sigan al acreedor.

La situación-tipo, que es la hipótesis abstracta, entra en juego, se aplica cuando se produce un hecho concreto que corresponda al modelo o esquema suyo, desencadenándose entonces los efectos que la norma prevé. En el ejemplo, realizada la hipótesis del no pago de la deuda por una persona determinada, se aplica la tesis, o sea, el deber de indemnizar los perjuicios nacidos del no cumplimiento exacto u oportuno de la obligación.

6) Generalidad. Las normas jurídicas además de abstractas, son generales.

Esto quiere decir que se dirigen a todos los coasociados que, durante el tiempo de su vigencia, encajen en las hipótesis por ellas previstas. En tales hipótesis pueden encontrarse todos los habitantes del territorio nacional, como cuando la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma señalada por la ley (artículo 19 N° 3); o sólo pueden encontrarse algunas personas, como las que contemplan las leyes que otorgan ayuda estatal a los habitantes de una zona afectada por un terremoto; e incluso puede encontrarse en la hipótesis prevista una sola persona. Ejemplo típico de este último extremo son los preceptos que se refieren al Presidente de la República, los cuales se aplican a cada ciudadano que, sucesivamente, ocupe ese cargo. Basta, pues, para que el mandato tenga el carácter de general el que sea susceptible de aplicarse a cualquiera que se halle en la hipótesis señalada.

La generalidad de las normas jurídicas responde al principio de igualdad ante la ley, pues la regla es la misma para todos, sin favorecer o perjudicar determinadamente a nadie. La generalidad evita la discriminación arbitraria. ¿Cómo se explican las leyes que se refieren nominativamente a una persona, cosa o relación? Ejemplos de esas leyes son las que reconocen a cierta persona años de servicios prestados en una repartición estatal; las que otorgan o privan de la nacionalidad a un sujeto; las que, por gracia, conceden a un individuo una pensión vitalicia. La explicación que suele darse a estas leyes con nombre y apellido es que, en verdad, no constituyen normas jurídicas, sino actos administrativos emitidos por el poder legislativo que revisten forma de ley, limitándose a constatar que la persona a que aluden se encuentra en la situación prevista por determinada norma general. Por ejemplo, cuando a un extranjero se le otorga por gracia la nacionalidad chilena, no se hace sino comprobar, por un acto administrativo dictado en forma de ley, que dicho extranjero cumple con las condiciones que establece la norma general del citado beneficio honorífico.

7) Coercibilidad. Las normas jurídicas son coercibles en el sentido de que admiten la posibilidad del cumplimiento forzoso cuando es necesario y factible. Tal posibilidad no se da en las normas morales, cuyo cumplimiento

depende sólo de la conciencia o voluntad del sujeto. Si éste desprecia un principio o una norma puramente moral nadie podrá forzarlo a respetarla y no tendrá otra sanción que el remordimiento, si es capaz de sentirlo, o la reprobación ajena. Principio ético y religioso es, por ejemplo, que el rico ayude al indigente, pero si no lo hace nadie podrá obligarlo a prestar ese auxilio.

8) Carácter estatal. La doctrina da a esta expresión dos significados.

- El Estado crea o reconoce las normas obligatorias generales, esto es, iguales para todos a cuantos afecte, como quiera que aspira mediante tales normas a realizar la justicia. El Estado es el que “habla o dice” el derecho.
- El segundo significado de la “estatalidad” es el de que el Estado garantiza el respeto o la observancia del ordenamiento jurídico. Y es explicable: sólo él se halla en condiciones de cautelar el orden y de poner a su servicio los medios coactivos para conservarlo.

Hay normas que emanan de otras fuentes, como la costumbre y las convenciones de Derecho Internacional; pero su eficacia dentro del ordenamiento de un Estado sólo surge cuando él les presta su conformidad o aprobación.

Es preciso considerar, en la época contemporánea, la tendencia internacional de ciertos organismos formados por varios Estados que, después de una convención o aprobación inicial de éstos, dirigen mandatos directos a las personas, empresas o entes que los componen, sin necesidad de que sean ratificados por los gobiernos de los países miembros. Así sucede con los Reglamentos de la Unión Europea.

3. Normas de orden público y normas de orden privado.

Normas de orden público: son aquellas a las cuales, en sus relaciones, los sujetos deben ceñirse ineludiblemente, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creación.

Las normas de orden público envuelven un predominante interés colectivo y, por ende, es lógico que sean el patrón común y uniforme de todas las relaciones a que ellas se refieren y no se alteren por la voluntad de las partes. Ejemplos típicos de estas normas son las que establecen solemnidades para algunos actos, como la escritura pública en la compraventa de bienes raíces; las que fijan la capacidad de las personas; las que protegen a los terceros de buena fe, etc.

Normas de orden privado: son las que, en sus relaciones, las partes pueden modificar o sustituir enteramente por otras elaboradas por ellas mismas. En consecuencia, estas normas que envuelven un puro interés de los sujetos de la relación, rigen cuando ellos no disponen otra cosa. Son, pues, supletorias de la voluntad de las partes. Ejemplo de norma de orden privado es la que prescribe que los gastos que ocasiona el pago de una obligación sean de cuenta del deudor; pero las partes, como no hay comprometido ningún interés social o de

terceros, pueden dejar de lado esta regla y convenir que dichos gastos sean solventados por el acreedor o a medias.

Suele decirse que las normas de orden público son irrenunciables, mientras que las de orden privado sí pueden ser renunciadas. Con esto se quiere significar que la aplicación de las primeras no puede descartarse, y sí la de las segundas.

Lo mismo quiere manifestarse cuando se afirma que las normas de orden público son indisponibles por las partes, y disponibles por ellas las normas de orden privado. Las partes disponen de las normas de orden privado cuando regulan sus propias relaciones jurídicas de manera convencional.

4. Derecho público y derecho privado

El Derecho (objetivo) es uno solo, pero, al igual que un árbol, presenta varias ramas. Estas divisiones o ramas se configuran por la diversidad que presentan ciertos grupos de normas respecto de otros.

Dos distinciones combinadas forman el cuadro más general del Derecho: por un lado está la distinción entre el derecho internacional y el derecho nacional, y por otro, la distinción entre derecho público y derecho privado.

La distinción entre derecho público y privado se hace tomando en cuenta copulativamente tres factores:

1. el interés preponderante que tutelan,
2. los sujetos de las relaciones
3. y la calidad en que ellos actúan.

El derecho público tutela preponderantemente un interés colectivo, y el derecho privado un interés particular, individual.

De acuerdo con el criterio señalado, el **derecho público** se define como el conjunto de normas que, mirando a un preponderante interés colectivo, regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos menores (como las municipalidades, por ejemplo), sus relaciones entre sí o con los particulares, actuando el Estado y dichos entes en cuanto sujetos dotados de poder soberano o público.

Dentro del derecho público los particulares actúan en un plano de subordinación frente a las entidades que obran en nombre de la soberanía nacional.

Derecho privado es el conjunto de normas que, considerando un preponderante interés individual, regulan las relaciones de los particulares entre sí o la de éstos con el Estado o los demás entes políticos en cuanto los últimos no actúan como poder político o soberano, sino como si fueran particulares, o, por fin, las

relaciones de estos mismos entes políticos entre sí en cuanto obran como si fueran particulares y no como poder político o soberano.

En el derecho privado se considera que las relaciones se establecen entre sujetos que intervienen en un plano de igualdad y ninguno de ellos como entidad soberana. Si el Estado expropia un terreno a un particular, actúa como poder político y la norma que rige este acto es de derecho público; pero si el Estado compra o toma en arriendo una casa a un particular o a una municipalidad, el derecho que regula la relación es el privado.

Para estos efectos es relevante tener en cuenta el artículo 19 N° 21 CPR, que señala en su inciso 3:

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado.

El hecho de que el Estado y los demás entes políticos actúen, a veces, como poder público y otras como si fueran sujetos privados no significa que tengan doble personalidad, una de derecho público y otra de derecho privado, pues su personalidad, en cualquiera órbita que actúen, es la de derecho público; sólo quiere decir que en un caso obran con atributos de superioridad y en el otro no.

Característica fundamental de las normas de derecho privado es que ellas contemplan preponderantemente el *interés particular* de los sujetos de la relación jurídica.

Una segunda característica de las normas de derecho privado es que éstas miran a las partes de la relación que gobiernan en un plano de *igualdad o paridad*, como quiera que fijan límites a los intereses de cada una de ellas.

5. No coincidencia entre las distinciones de normas de derecho público y de derecho privado y la distinción de normas de orden público y de orden privado.

Estas dos distinciones no coinciden, porque atienden a factores diferentes. La distinción entre normas de derecho público y de derecho privado se hace considerando las personas que intervienen en la relación regulada y la calidad en que obran; en cambio, la distinción entre normas de orden público y de orden privado está fundada en la posibilidad o no de ser dispuestas por las partes de la relación que se regula: las de orden público, por implicar preponderantemente un interés colectivo, no pueden ser descartadas o alteradas por dichas partes, y sí lo pueden ser tratándose de normas de orden

privado.

Los textos legales (Constitución Política, Códigos, leyes en general) se califican de derecho público o de derecho privado, según tengan uno u otro carácter la gran mayoría (no todas) de las normas que contienen.

En un texto de derecho público puede haber normas de orden privado. Por ejemplo, la Constitución Política contempla la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, pero entre las normas que la regulan hay una de orden privado, como es la que establece la obligación del Estado de indemnizar al expropiado (artículo 19, N° 24 inciso tercero). Esta norma es de orden privado porque no cabe poner en duda que el derecho a ser indemnizado puede renunciarse por el expropiado. Asimismo, en un Código privado se encuentran a menudo normas de orden público que representan un interés prevalentemente colectivo; por ejemplo es de orden público la norma que establece la nulidad absoluta de un acto o contrato porque no puede sanearse por la ratificación de las partes (C. Civil, art. 1683).

No siempre las normas de orden público proclaman su carácter al establecer ellas mismas su indisponibilidad, por lo que cuando no sucede así toca al intérprete determinar si la norma es de orden público o de orden privado que, como advierten los autores, no siempre es asunto fácil.

6. Diferencias entre el derecho público y el derecho privado

Diversos criterios se han propuesto para diferenciar el derecho público y el derecho privado; todos han merecido serios reparos. A la postre, la diferencia esencial es la que resulta de las definiciones que hemos dado de ambos derechos:

- Mientras el público regula relaciones en que interviene el Estado u otro ente político menor como titular de la soberanía o de un poder público,
- El derecho privado regula relaciones en que sólo intervienen particulares o, si lo hace el Estado o alguno de los entes políticos menores, actúa como si fuera un sujeto particular.

1.2 DERECHO CIVIL

1. Generalidades.

Civil es palabra que deriva del latín *civilis*, de *civis*: ciudadano. En consecuencia, etimológicamente, derecho civil quiere decir derecho concerniente al ciudadano; traducido en el lenguaje jurídico más exacto de hoy significa el derecho propio de los nacionales de un país o Estado.

2. Definición.

Hoy el **derecho civil** puede definirse sintéticamente como el derecho privado común, general y supletorio; en forma descriptiva, como el conjunto de normas sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia.

3. Contenido.

El contenido del derecho civil moderno lo forman las normas sobre las instituciones fundamentales del derecho privado que se refieren a todas las personas, sin distinción de su condición social, profesión, etc. Estas instituciones son la personalidad, la familia y el patrimonio.

1) Las **normas sobre *la personalidad*** miran a la persona en sí misma, con prescindencia de sus relaciones familiares o patrimoniales con los demás. Disciplinan la existencia, individualización y capacidad de las personas físicas y morales o jurídicas.

2) Las **normas sobre *la familia*** rigen la organización de ésta y, dentro de ella definen el estado de cada uno de sus miembros: cónyuge, hijos matrimoniales y no matrimoniales, etc.

3) Las **normas sobre *el patrimonio***, es decir, sobre el conjunto de derechos y obligaciones valuables en dinero, regulan los derechos siguientes:

a) Los derechos reales y los derechos sobre bienes inmateriales (obras literarias, marcas de fábrica, etc.). Algunos autores comprenden ambas clases de derechos bajo el nombre común de *derechos de exclusión*, porque ellos excluyen del goce de las cosas corporales o incorporeales a toda otra persona que no sea el titular de los derechos que sobre ellas recaen.

b) Los derechos de obligación, en virtud de los cuales una persona (acreedor) está facultada para exigir de otra (deudor) una prestación en interés de la primera. Tradúcese la prestación en una acción positiva (dar, hacer) o en una abstención (no hacer). Hay, pues, obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.

c) Los derechos de sucesión por causa de muerte, que regulan la transmisión de los bienes o patrimonio de una persona por causa de la muerte de ella.

4. Ubicación del Derecho Civil dentro de las ramas del Derecho

El Derecho Civil se ubica dentro de las ramas del derecho privado. Es el derecho privado general, común y supletorio. Es general porque gobierna las relaciones jurídicas ordinarias más generales del ser humano en cuanto tal, con prescindencia de cualquiera otra circunstancia (nacionalidad, profesión, etc.)

Es también común el derecho civil, porque todas las relaciones jurídicas privadas de los hombres que no están disciplinadas por otra rama especial o autónoma del derecho, son regidas por el derecho civil, y es común, asimismo, porque sus principios o normas generales suplen los vacíos o lagunas de las ramas especiales del derecho privado. Estas últimas con respecto al derecho civil son especiales porque, en su ámbito respectivo, derogan o modifican las normas civilistas. Pero cuando un derecho especial carece de regulación propia sobre una materia o situación, mantiene su imperio general el derecho civil. Así, por ejemplo, el Código especial llamado Código de Comercio declara que cuando sus preceptos no resuelven especialmente un caso se apliquen las disposiciones del Código Civil (art. 2º).

5. Importancia del Derecho Civil

La importancia del Derecho Civil radica, en:

- 1) Su vasto contenido, porque a pesar de los desmembramientos sufridos continúa siendo la disciplina mayor, pues abarca todas las relaciones jurídicas no comprendidas en los ordenamientos especiales.
- 2) Generalidad de su aplicación; sus normas suplen los vacíos de los derechos especiales. Este carácter supletorio erige al Derecho Civil en un elemento de unidad y cohesión de todas las ramas del derecho privado.
- 3) Técnica de sus principios, afinada durante siglos; ella informa o sirve de pauta a la de los derechos especiales.
- 4) Sus teorías fundamentales, sobre las personas, los bienes, los hechos y actos jurídicos en general, proporciona a los derechos especiales, los cuales adoptan esas teorías con o sin modificaciones.

1.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CÓDIGO CIVIL.

El Código Civil chileno comprende:

- Un título preliminar
- Cuatro libros, seguidos del
- "Título final".
- Cada libro se divide en títulos y muchos de estos en párrafos.
- Por último, el Código se distribuye en artículos desde el 1º al 2524, más el artículo final.

El "Título preliminar" trata:

- Todo lo relativo a la ley (concepto, promulgación, obligatoriedad, efectos en el tiempo y en el espacio, su derogación e interpretación)
- Da la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes: "Consigna nociones y definiciones que se refieren igualmente a todas

las ramas del Derecho. Se las ha colocado en este Código por ser el más general y porque fue el primero que se dictó entre nosotros”.

- También, en los arts. 14 a 18 contiene normas fundamentales de Derecho Internacional Privado.

El **libro I** se titula "*De las personas*". Habla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio; del principio y fin de su existencia; del matrimonio; de las diferentes categorías de hijos; de las pruebas del estado civil; de la emancipación, de las tutelas y curatelas; de las personas jurídicas, etc.

El **libro II** se titula "*De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce*". Ocupase de las variadas clases de bienes, del dominio o propiedad, de los diversos modos de adquirir ésta, de la posesión de los bienes, de las limitaciones del dominio (propiedad fiduciaria, derecho de usufructo, derechos de uso y habitación, las servidumbres prediales), la reivindicación, y de las acciones posesorias.

El **libro III** se denomina "*De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos*". Trata de la sucesión intestada, o sea, señala quienes heredan los bienes del difunto cuando éste no ha hecho testamento, de los testamentos, de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas, de los ejecutores testamentarios, de la partición o reparto de los bienes del difunto, del pago de las deudas hereditarias y testamentarias, de las donaciones entre vivos.

El **libro IV**, titulado "*De las obligaciones en general y de los contratos*", habla de las diferentes clases de obligaciones; del efecto de ellas; de los modos de extinguirlas (pago efectivo, novación, remisión, etc); de su prueba; de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, de la separación de bienes y del régimen de participación en los gananciales; de las diversas clases de contratos (compraventa, arrendamiento, sociedad, etc.), de su interpretación; de los cuasicontratos; de los delitos y cuasidelitos civiles; de la fianza; de la prenda; de la hipoteca; de la anticresis; de la transacción; de la prelación de créditos, y de la prescripción.

El **título final** consta de un solo artículo que se refiere a la observancia del Código.

Por último, **el mensaje** del Código Civil, aunque formalmente no constituya parte de su estructura, tiene cierta relevancia práctica. En él constan muchos de los objetivos que el legislador perseguía por medio de su promulgación, y se explican los principios generales de varias instituciones relevantes. En ese sentido, su contenido resulta fundamental para materias tales como la interpretación del Código Civil.

1.4 PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL CÓDIGO CIVIL.

Según el jurista norteamericano Ronald Dworkin¹, el derecho no está compuesto exclusivamente de reglas, sino que también está integrado por principios. En su opinión, es posible distinguir los principios de las reglas atendiendo a dos criterios:²

i) Forma de aplicación:

- Las reglas vinculan un supuesto de hecho preciso con una consecuencia jurídica determinada. De esta manera, tienen una aplicación del tipo "todo o nada", es decir, si se da el supuesto de hecho, se aplica la consecuencia jurídica. Si no se da el supuesto, no se aplica la consecuencia.
- Los principios no presentan esta estructura "todo o nada". Más que vincular supuestos de hecho precisos con consecuencias jurídicas determinadas, vinculan supuestos de hecho genéricos con razones que apuntan hacia una dirección determinada, pero no a una consecuencia precisa.

ii) El problema de la ponderación o el peso:

- Como consecuencia de lo anterior, las reglas no admiten ambigüedad de ningún tipo. O se aplican o no se aplican. La tarea del jurista es determinar cuáles son los supuestos de hecho, identificar la regla aplicable, y extraer la consecuencia jurídica que la regla ordena. Dos reglas válidas no pueden estar en contradicción³.
- Los principios, en cambio, sí incorporan este elemento de la ambigüedad. Así, el jurista debe identificar los elementos de hecho, identificar los principios aplicables, y ponderar, según los elementos del caso, a cuál principio debe dársele más peso. Así, dos principios pueden estar en contradicción.

Así, los principios generales del Derecho Civil son ideas inspiradoras relevantes que explican el fundamento de la generalidad de las normas del Derecho Privado y permiten una adecuada armonía y vinculación entre ellas. Por medio de los principios es posible darle al derecho mayor versatilidad, y hacerse cargo de situaciones de hecho que no necesariamente están claramente previstas en las reglas propiamente tales.

Sin bien muchos de estos principios no están expresamente textualizados en alguna disposición normativa específica, igualmente se presentan inversos en muchas de ellas, desprendiéndose de ciertas deducciones lógicas.

No es fácil dar una enumeración acabada de estos, por lo cual no limitaremos a señalar algunos de ellos, los que a nuestro parecer tienen una especial importancia. Para efectos de ofrecer una clasificación sistemática,

¹ Dworkin, Ronald. *Una cuestión de principios*. Buenos Aires: Siglo XXI editores (2013)

² Para más detalles, consultar:

<http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/100/la-teoria-de-los-principios.pdf>

³ Las antinomias que, de hecho, se puedan generar, deben ser resueltas en términos de identificar cuál es la regla general y cuál es la excepción. Para esta tarea, justamente, los principios son un buen medio auxiliar.

distinguiremos los principios clásicos que inspiraron el Código Civil de los así llamados "principios modernos", que han sido incorporados por medio de nuevas leyes, la suscripción a tratados internacionales o de la evolución dogmática de nuestra legislación civil:

Los principios que inspiraron directamente el Código Civil son:

1. Reconocimiento de la Autonomía de la Voluntad
2. La protección a la propiedad privada
3. La libre circulación de la riqueza
4. Protección a la buena fe (y consecuentemente el castigo de la mala fe)
5. Reparación del enriquecimiento sin causa
6. Igualdad
7. Responsabilidad

Los modernos principios del derecho civil son:

1. El interés superior de los hijos y, en particular, de los no emancipados
2. La protección al cónyuge más débil
3. El derecho a la identidad y a la dignidad personal
4. La reparación integral del daño

Los principios fundamentales que inspiran el Código Civil chileno son:

1) Reconocimiento de la Autonomía de la Voluntad:

El principio de la Autonomía de la Voluntad consiste en el reconocimiento de todas las personas como sujetos libres y autónomos que, en virtud de su condición de seres racionales, pueden darse a sí mismos sus propias normas. Así, el principio de la autonomía de la voluntad se traduce en el reconocimiento de la autonomía privada, esto es, la capacidad que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares para regular sus relaciones jurídicas según sus propios intereses, por medio de la creación de sus propios actos jurídicos. El autor del acto jurídico o las partes de la convención podrán, en consecuencia, dar el contenido negocial que deseen a sus actos jurídicos, modificar las normas de orden privado establecidas para determinados actos o contratos, o incluso contratar sobre materias no contenidas en el Código Civil, siempre que no transgredan los límites de la ley, el orden público y las buenas costumbres. Por esto es que se suele señalar que la voluntad es la "fuente y medida" de los derechos y las obligaciones.

Una de las manifestaciones más claras del principio en cuestión, el art. 1444 CC, establece la facultad de las partes de modificar las cosas de la naturaleza de un contrato o agregarle cosas accidentales por medio de las cláusulas especiales emanadas de su voluntad. Por otra parte, una vez perfeccionado el contrato, el art. 1545 dispone que, "el contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino

por su consentimiento mutuo o por causales legales”.

Esta disposición establece toda la fuerza de la declaración de la voluntad, y demuestra que la contracara del reconocimiento de esta autonomía es la obligatoriedad para el propio agente de la regulación que este se da a sí mismo. Por consiguiente, el acuerdo celebrado entre las partes tiene el carácter de una verdadera ley para ellos. Si bien esta ley no tiene la ejecutoriedad general como la que sí posee el art. 1º del CC, tiene completa validez y obligatoriedad en el ámbito de sus relaciones recíprocas.

Ahora bien, es necesario señalar que el principio de la autonomía de la voluntad no opera de manera uniforme en todas las materias que regula el derecho civil. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la distinción entre el derecho civil patrimonial y extrapatrimonial, veremos que en las materias extrapatrimoniales la autonomía de la voluntad está sumamente restringida por la gran cantidad de normas de orden público que regulan dichas materias. Esto se debe al tipo de bienes jurídicos que subyacen a la regulación del derecho civil extrapatrimonial.

Se ha sostenido que la autonomía de la voluntad en el Derecho Civil se está desvaneciendo, que cada día más existe tendencia del derecho privado a transformarse en público, la cantidad de normas que imponen regulaciones de carácter irrenunciable y no supletorio a la esfera privada. Pero estas regulaciones vinculantes contenidas en la ley pública no afectan el carácter de privado de las normas de nuestro Código Civil, sino sólo establecen limitaciones por diferentes razones a las personas que al momento de realizar sus actos jurídicos, deben respetar so pena de ineficacia de los mismos.

La autonomía de la libertad siempre ha tenido límites, precisamente porque la libertad de cada uno debe ajustarse a un marco general que la haga posible en coexistencia con la libertad de todos.

Tales limitaciones son:

i. La Ley, ésta limitación se presenta en dos aspectos:

- Un acto voluntario no puede transgredir la ley.
- Dicho acto no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables. Hacemos referencia al art. 12, ya que la prohibición de renuncia fuera de no respetarla constituirá una infracción legal dentro del contexto que hemos analizado sobre tal precepto.

ii. La protección del orden público y a las buenas costumbres:

El legislador nunca ha dado un concepto de orden público, se ha definido como “la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad”. Nuestro Código Civil se refiere a él en cinco de sus disposiciones en los arts. 548 y, 880, 1461, 1467 y 1475.

Con relación a las buenas costumbres el Código Civil se refiere a ellas en los arts. 548, 1461, 1467, 1475 y 1717. Corresponde a aquellos usos uniformes que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social. No se trata de usos cuya contravención esté penada por la ley, porque entonces nos encontraríamos en presencia de una infracción legal. Es un concepto difícil de precisar y que cambia de una sociedad a otra o dentro de la misma por el transcurso del tiempo.

iii. La protección de los derechos legítimos de terceros:

La autonomía de la voluntad tiene una clara y amplia limitación en cuanto no puede atentar contra los derechos legítimos de los terceros. Un claro ejemplo de ello, lo encontramos en el art. 582, que al definir el dominio.

2) La protección a la propiedad privada

En nuestro Código Civil el derecho de propiedad constituye uno de los pivotes de la estructura social, dedicando gran parte del Código a su regulación, teniendo como punto de partida el libro II, que trata precisamente de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce.

El derecho civil entiende que la base de la organización de la sociedad es la libertad, y que el ejercicio efectivo de la libertad requiere garantizarle a las personas su derecho de propiedad como espacio efectivo en que pueden ejercer esa libertad.

Así, nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de garantías constitucionales que protegen el derecho de propiedad de los particulares. En conjunto con lo anterior, el derecho civil establece un conjunto de mecanismos para proteger al dueño ante cualquier afectación de su propiedad. Esta protección puede ser:

a. Protección Directa:

- i. Acciones que eliminan perturbaciones ya consumadas: Acción reivindicatoria.
- ii. Acciones que previenen un daño: Acciones o interdictos posesorios de denuncia de obra nueva y obra ruinosa. Acciones de demarcación y cerramiento.

b. Protección Indirecta:

- i. Acciones posesorias.
- ii. Acción publiciana.
- iii. Tercería de posesión.

c. Acciones personales:

- i. Ejemplo: Acción de restitución en el comodato o en el arrendamiento (derivada de la obligación personal que emana del contrato).

3) La libre circulación de la riqueza.

Fruto de las ideas postuladas en la Revolución Francesa y recepcionadas por el código napoleónico. Se concibe a la propiedad privada libre de gravámenes, permitiendo una libre circulación de la riqueza. El Derecho Civil promueve un flujo de bienes mediante un tráfico jurídico libre y sin trabas, lo que se traduce en el principio de la libre circulación de la riqueza. Se considera que, mientras a más manos acceda, mayor es la riqueza que proporciona y por ende mayor el beneficio social que la propiedad tiene de por sí.

En consecuencia, el contenido esencial de este principio consiste en la protección de las facultades del dueño en términos de poder enajenar las cosas, y en la restricción a los impedimentos que terceros podrían establecer en relación a dichas facultades.

Recogen estos principios los siguientes artículos del Código Civil.:

- El art. 582: al definir el dominio o propiedad;
- El art. 745: al prohibir los fideicomisos sucesivos;
- El art. 769: al prohibir los usufructos sucesivos o alternativos;
- El art. 1126, que en principio, establece la ineficacia de la prohibición de enajenar, impuesta al legatario, a menos que comprometa derechos de terceros;
- El art. 1317: al establecer que siempre podrá pedirse la partición de la comunidad;
- El art. 1964, en el arrendamiento, que faculta al arrendador para enajenar el bien arrendado, incluso habiendo estipulado con el arrendatario prohibición de hacerlo;
- El art. 2031, que faculta al dueño de la finca gravada con un censo, para enajenarla;
- El art. 2415, que deja en claro que el dueño de la finca hipotecada, siempre podrá volver a hipotecarla o derechamente enajenarla, aún habiendo obligado a no hacerlo.

4) Protección a la buena fe: (y consecuentemente el castigo de la mala fe).

La buena fe es un principio fundamental en el derecho civil. En términos generales, podemos decir que la buena fe dice relación con la idea de una voluntad y una conciencia dirigidas a obrar rectamente y de manera justa. Podemos decir que esta idea general de la buena fe se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones del derecho civil, pues el obrar recta y justamente de los ciudadanos es, precisamente, uno de los fines del derecho.

Ahora bien, de manera más concreta, esta idea general de la buena fe se traduce en dos facetas, caras o aspectos de la buena fe: buena fe en sentido

objetivo y buena fe en sentido subjetivo.

i) Buena fe objetiva: Se encuentra consagrada en el artículo 1546 CC, a propósito de los efectos de las obligaciones. "Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella."

Vemos que la buena fe objetiva se refiere a la conducta externa de las personas. La buena fe objetiva consiste en *actuar* de buena fe.

ii) Buena fe subjetiva: Se encuentra consagrada en el artículo 706 CC, a propósito de los requisitos de la posesión regular. "La buena fe consiste en la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio".

La buena fe subjetiva, a diferencia de la objetiva, se refiere a un estado mental, interno a las personas. La buena fe subjetiva consiste en *estar* de buena fe.

La importancia de la buena fe objetiva radica en las funciones que cumple en el derecho de los contratos y, por extensión, del acto jurídico en general: la buena fe provee un estándar de conducta y un criterio de interpretación para los contratos y los actos jurídicos en general. La buena fe rige en todas las etapas del íter contractual, desde las tratativas preliminares, la celebración del contrato, su ejecución e incluso posteriormente a esta.

La importancia de la buena fe subjetiva radica en que el derecho civil en general, y no sólo en materia posesoria, protege a quien actúa persuadido por la sincera creencia de estar obrando conforme a derecho. Incluso, si esta creencia está basada en un error de hecho, el derecho protegerá al que actuó de buena fe, siempre y cuando dicho error sea excusable.

La buena fe en el derecho civil se presume. El Código siempre parte desde la premisa de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Esta presunción está consagrada en el artículo 707 del Código Civil: *"La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse."*

Las presunciones de mala fe son escasas:

- Art. 706 incº final CC: "Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario."
- Art. 94 nº6 CC: "El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe."

- Art. 968 nº5 CC: "el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación."
- Art. 280 del Código de Procedimiento Civil, en relación a quien solicita una medida prejudicial precautoria y luego no deduce la demanda en tiempo oportuno.

Por último, es necesario aclarar la relación entre dolo y mala fe. Para la gran mayoría de la doctrina, ambos conceptos son sinónimos y, por tanto, intercambiables. No obstante, algunos profesores distinguen ambos conceptos señalando que comparten el elemento cognitivo (saberse en una posición contraria a derecho), mientras que se diferenciarían porque solo en el dolo está el elemento volitivo (querer actuar de manera contraria a derecho), ausente en la mera mala fe.

5) Reparación del enriquecimiento sin causa:

En términos generales es aquel el enriquecimiento que se produce en el patrimonio de una persona, en desmedro de otro, sin una causa legítima que lo justifique. El derecho no sanciona que una persona se enriquezca sino lo que el derecho busca reparar que una persona se empobrezca sin motivos o por motivos injustos.⁴

Tendrá causa legítima, por ejemplo, en la venta, donación, una asignación por causa de muerte, etc. Pero puede acontecer que el enriquecimiento sea ilegítimo, que carezca de causa justificada, como ocurre cuando se paga lo que en realidad no se debe. En tal caso, se produce enriquecimiento sin causa.

El Código Civil no consagra ninguna norma general que establezca como fuente de las obligaciones al enriquecimiento sin causa. Sin perjuicio de ello, son variadas las instituciones que se fundan en la necesidad jurídica de reparar el enriquecimiento sin causa. Dentro de ellas destacamos:

1) Los cuasicontratos son la expresión más clara de la reparación al enriquecimiento sin causa. Así, la regulación del pago de lo no debido, de la agencia oficiosa y de la comunidad tienen su fundamento en este principio.

2) Las recompensas que se deben por la sociedad conyugal a los cónyuges y por éstos a la sociedad. Se pretende con estas recompensas evitar un

⁴ Daniel Peñailillo considera que la esencia del enriquecimiento sin causa no es el desplazamiento de riqueza de un patrimonio a otro, sino la atribución de riqueza en el patrimonio de una persona que no tiene título o causa para recibir. Así, no solo habría enriquecimiento injustificado si una persona se enriquece a costa de otra, sino también cuando se crea riqueza nueva y una persona se aprovecha de ella sin título para retenerla, aunque nadie se empobrezca.

enriquecimiento injusto de un cónyuge a expensas del otro. Art. 1725 CC y siguientes.

3) Las prestaciones mutuas que se deben el reivindicante y el poseedor vencido. Art. 904 CC y siguientes.

4) La regla del art. 1688 establece una excepción a los efectos de la nulidad como medida de protección en favor del incapaz. No obstante, también establece una contraexcepción: se obliga al incapaz a restituir aquello en que se hubiere hecho más rico.

Como se ve, la consagración del principio de la reparación al enriquecimiento sin causa no es orgánica, sino casuística. En ese sentido, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si es que se genera una situación de enriquecimiento sin causa y no hay una regla especial que corrija dicha situación? En estos casos, la doctrina y la jurisprudencia han construido una acción que permita reparar esta injusta lesión en aquellas situaciones de enriquecimiento injusto no cubierto por una norma especial. Esta acción se denomina acción in rem verso.

La doctrina ha enunciado en términos generales los requisitos que hacen procedente la acción in rem verso:

1) Que una persona se haya enriquecido.

El enriquecimiento puede ser material y también intelectual o moral. De igual forma, el enriquecimiento podrá consistir no solamente en la obtención de una ganancia, sino también en la economía de un desembolso. Este enriquecimiento, y no el empobrecimiento correlativo, es la medida de la obligación restitutoria.

2) Que correlativamente, otra persona se haya empobrecido.⁵

No siempre se requiere acreditar una pérdida o empobrecimiento material, una efectiva disminución patrimonial. También experimentará un empobrecimiento el que prestó un servicio o efectuó un trabajo que no fue remunerado.

3) Que el enriquecimiento sea injusto, ilegítimo o sin causa.

El enriquecimiento debe carecer de un título que lo justifique, como la venta, la asignación hereditaria. Como lo normal es que el enriquecimiento tenga una causa justificada, deberá probarse su ausencia por quien deduce la acción in rem verso.

⁵ Este requisito ha sido discutido por la doctrina contemporánea. Daniel Peñailillo sostiene que dicho empobrecimiento correlativo no es necesario. Ejemplo: A se va de viaje por tres meses, dejando su parcela cerrada. B le arrienda a C la parcela de A, percibiendo una renta por ello. Al volver A, encuentra su parcela intacta. Según esta tesis, A tendría acción contra B pues, aunque A no se haya empobrecido, B se enriqueció sin un título que lo justifique.

4) Que la víctima no tenga otro medio que la acción in rem verso para obtener la reparación.

De lo expuesto se establece que esta acción es de carácter subsidiario. Sólo puede interponerse cuando la víctima carece de otro medio para obtener que se repare el perjuicio.

En cuanto a los efectos de la acción, la finalidad que persigue es la obtención del reembolso de aquello en que el demandado se ha enriquecido. Con todo, puede suceder que el enriquecimiento sea mayor que el empobrecimiento sufrido por el demandante. En tal caso, el reembolso no podrá exceder del monto del empobrecimiento, correspondiendo la diferencia al demandado.

5) Igualdad:

El Derecho Civil clásico resguarda la igualdad de las personas, en forma directa y en un doble sentido. Por una parte, consagrando la igualdad entre chilenos y extranjeros en la adquisición y goce de los derechos civiles que regla el código y, por la otra, mediante el establecimiento de incapacidades generales -absolutas o relativas- o de incapacidades especiales o prohibiciones. Así sucede en las guardas, en los actos patrimoniales, en el matrimonio, en la filiación y en el testamento, todas ellas fundadas en el resguardo del interés general o en el estado o calidad de las partes.

El establecimiento de incapacidades puede ser considerada como una manifestación del principio de igualdad, pues dicho principio no solo implica tratar igual a todos sin distinción. También implica tratar de manera diferente a aquellas personas que presenten alguna diferencia, siempre y cuando la diferencia de trato esté justificada en la protección de dicha diferencia.

Este principio también es una consecuencia de los postulados, en la época en que se redacta el Código recientes, de la Revolución Francesa, entre ellos, el principal: todas las personas nacen iguales, "en dignidad y derechos", como reza nuestra Constitución Política.

Se recepciona el principio en los siguientes arts. del Código:

- en el art. 14.
- En el art. 33, el establecer que la ley considera iguales a todos los hijos;
- En el art. 55, al definirse a las personas naturales;
- En el art. 57, al establecerse la igualdad entre chilenos y extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles;
- En el art. 75, en cuanto a la protección del que está por nacer;
- En el artículo 982, al establecerse que en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura;
- En el artículo 997, al establecerse que los extranjeros son llamados

de la misma manera que los chilenos, a las sucesiones abintestato abiertas en nuestro país;

- En el art. 2497, al disponer que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra de todas las personas naturales capaces y personas jurídicas de derecho público o de derecho privado;

6) Responsabilidad: La responsabilidad puede definirse en términos generales como el juicio normativo que permite atribuir efectos patrimoniales en un sujeto cuando ha provocado daño en la persona o patrimonio de otro. En términos más específicos, puede definirse como la obligación de constituirse en garante del daño causado ya sea por el incumplimiento de una obligación (responsabilidad contractual) o por la ejecución de un hecho (responsabilidad extracontractual).

La ley es un precepto emanado del Estado y lleva aparejada una sanción. La más general de estas sanciones, ya sea porque se infrinja o no se cumpla un precepto legal, ya sea porque se desarrolle una conducta antijurídica, es la responsabilidad.

Esta responsabilidad puede significar:

- una pena cuando se ha cometido un delito,
- o bien, indemnizar un perjuicio o resarcir un daño, como sucede en la responsabilidad civil.

En materia de Derecho Civil, suelen distinguirse dos campos de responsabilidad en relación al hecho ilícito generador de la obligación indemnizatoria:

- Responsabilidad Civil Contractual: aquella se genera frente al incumplimiento del contrato por parte de una de las partes, incumplimiento que puede ser total o parcial, y deberse a negligencia, imprudencia, culpa o dolo. Relevantes en este sentido, son por el momento los arts. 1556 y 44. Cuando se genera el incumplimiento unido a otros requisitos legales, el acreedor de la obligación y por lo mismo titular del crédito o derecho personal (art. 578) recordando la definición de obligación como un vínculo jurídico que en este caso nació de la fuente "contrato" tiene una serie de mecanismos para obtener el cumplimiento de la obligación en forma forzosa, ya sea en naturaleza ya sea en equivalencia. Cuando se produce el cumplimiento por equivalencia, estamos frente a la responsabilidad civil contractual, es decir aquella que emanó del incumplimiento de la obligación contractual.

- Responsabilidad Civil Extracontractual: aquella que se configura a través de la comisión de un delito o cuasidelito civiles que los arts. 1437 y 2284 señalan como fuente de las obligaciones. La obligación que de ellos nace es precisamente indemnizar el daño causado. Por provenir de la ejecución de un hecho ilícito, doloso o culpable, no supone la existencia de ningún vínculo jurídico previo, sino solo el deber jurídico de no causar daño a otro.

Se encuentra reglamentada en el título cuarto de nuestro Código, en los arts. 2314 y siguientes.

Entre los modernos principios del derecho civil, podemos citar los siguientes:

a. El interés superior de los hijos, y en particular de los no emancipados.

Este principio se instauró en nuestro Derecho con la ratificación de la Convención Sobre los Derechos del Niño (publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de septiembre de 1990), y en el Código Civil, a consecuencia de la reforma que a sus normas introdujo la Ley número 19.585, de 26 de octubre de 1998. En este sentido, el Código Civil, alude a este interés en diversos artículos, como por ejemplo 147, 201, 222, 225, 229, 234, 236, 242, 244, 245, 254, 255, 321, 1792-21, etc.

Por ello, bien podemos afirmar que hoy, es uno de los principios fundamentales del Código Civil chileno. Cabe advertir que este principio no está circunscrito exclusivamente a los hijos menores de edad, aunque la mayoría de las normas que lo consagran se refieren a ellos.

b. Protección al cónyuge más débil.

Este principio se recoge en diversas materias de la Ley de Matrimonio Civil. El art. 3º de este cuerpo legal, establece "Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil". Así, en el marco de esta ley, opera el principio en materias tales como la necesidad de presentar acuerdos regulatorios, tratándose de la separación de hecho, de la separación judicial, del divorcio, o de la nulidad, así como en lo concerniente a la compensación económica a que tiene derecho el cónyuge más débil, tratándose del divorcio y de la nulidad.

c. El derecho a la identidad y a la dignidad personal.

Se manifiesta fundamentalmente en el derecho a nacer, propiciado por el reconocimiento a la existencia natural y legal, el derecho a conocer su verdadera filiación o investigación de la paternidad o maternidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho al domicilio y el derecho a la capacidad de goce.

D. Reparación Integral del daño: En atención al artículo 2329 del CC y la expresión "todo daño", comenzó a incluirse dentro de la indemnización de perjuicios en los años 1920 la reparación del daño moral sufrido por la víctima. Por principios de equidad y específicamente de la igualdad ante la ley y la igualdad en el ejercicio de los derechos, comenzó además a ser indemnizado a partir de la década del 50' en materia contractual.

CAPÍTULO 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.

2.1 CONCEPTOS GENERALES.

El derecho en cuanto fenómeno cultural se encuentra determinado por las circunstancias históricas en que se desarrolla.

Concepto de fuente de derecho: toda constancia escrita o verbal que permita captar la existencia de normas jurídicas.⁶ Se refiere al nacimiento de sus normas y evoca dos cuestiones diferentes:

a. Fuentes materiales: aluden a los factores y elementos que explican el nacimiento y determinan el contenido de las normas jurídicas, constituyendo incluso elementos importantes para su interpretación. Ejemplo: artículo 2314 tiene como fuente material el Código Civil francés, juristas de la ilustración, principios técnicos del racionalismo o al casuismo del derecho romano. Además del sustento valórico de la libertad de las personas. Son las manifestaciones escritas o verbales que no establecen normas jurídicas, sino que aportan elementos para el conocimiento de ellas.

b. Fuentes formales: el concepto se refiere al origen inmediato de las normas, lo que determina la forma como estas se expresan. Las normas adquieren forma jurídica por diversas vías dependiendo del momento. Por ejemplo mediante la costumbre, las sentencias judiciales y la ley. Los tres primeros artículos del Código Civil revelan que la ley tiene una condición por completo determinante, la costumbre se subordina a ella y las sentencias se limitan a los casos en que se pronuncian. Están expresadas y referidas en una forma.

De esta forma, las fuentes formales del derecho en Chile serían, únicamente, la ley y la costumbre, toda vez que estas son las únicas fuentes con validez generalmente obligatoria. Ahora bien, en relación a la sentencia judicial, esta no es, al menos en principio, una fuente formal del derecho. Nuestro ordenamiento jurídico sigue la tradición continental que, a diferencia de la tradición del Common Law, no le reconoce a la sentencia judicial una fuerza generalmente obligatoria tal como la de la ley. La sentencia judicial sería una fuente auxiliar del derecho o, a lo más, una fuente formal indirecta, en el sentido de que no contiene normas generalmente obligatorias, sino solo las explica.

No obstante lo dicho en el párrafo anterior, como veremos más adelante, esto último está en entredicho, pues la incorporación de ciertos recursos procesales cuyo fundamento es la existencia de sentencias contradictorias ha tendido a darle un mayor peso a la jurisprudencia en relación al derecho vigente.

El análisis comparado de las fuentes muestra que la ley y la costumbre son los

⁶ Revisar anexo al final acerca de las diferentes clasificaciones de las fuentes del derecho

principales tipos de fuentes en la historia del derecho y en el derecho comparado.

A modo de introducción, podemos señalar que:

- La ley tiene la ventaja de ser la más dinámica y eficiente en cuanto al cambio. Puede ser derogada, modificada y sustituida con rapidez siguiendo los procedimientos preestablecidos. Además se sabe el momento exacto del comienzo y término de su vigencia. Produce mayor seguridad jurídica y puede invocarse con facilidad.
- La costumbre tiene su origen en la repetición constante, uniforme y antigua de ciertos modos de conducta, unida al convencimiento colectivo de que obedecen a una necesidad jurídica. Tiene la ventaja de estar apegada al espíritu jurídico espontáneo. Es válida porque la gente estima que su contenido es justo y obligatorio. Su cambio es mucho más lento que la ley.

El derecho chileno tiene una fuerte vocación legislativa por las influencias ideológicas de la ilustración y por razones históricas: luego de la Independencia, la manera más eficaz de crear un derecho nacional fue mediante la legislación.

Entre nosotros, la fuente fundamental es la ley. La equidad es un elemento de integración de la ley. Esta misma y el espíritu general de la legislación son base de la interpretación de la ley.

El término ley como fuente formal encierra dos acepciones:

- (1) Externa: precepto dictado por el Estado con carácter obligatorio.
- (2) Interna: prescripción de conducta que encierra el precepto, y que es la norma jurídica.

CAPÍTULO 3. LA LEY.

3.1 CONCEPTO.

Concepto doctrinario de ley: es una fórmula precisa dictada por órganos soberanos especiales; es un mandato expreso que proviene de la voluntad del legislador, formulado en palabras determinadas y a través de un procedimiento establecido.

La CPol regula la (1) materia, (2) formación y (3) alcance de la ley. El primer límite a este alcance está en las garantías constitucionales.

Definición de Planiol: la ley es una regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LEY EN CUANTO A SU CONTENIDO.

- 1) Es una regla social, una norma de conducta exterior.
- 2) Emana de la autoridad pública.
- 3) Debe ser cumplida, no es facultativo para los individuos acatarlas o no.
- 4) Es sancionada por la fuerza.
- 5) Es general y abstracta.
- 6) Es permanente, dura desde su promulgación hasta su derogación. Pero no es perpetua: hay leyes temporales y leyes transitorias.
- 7) Es cierta, no necesita ser acreditada.

3.3 DEFINICIÓN DEL CC.

Art. 1º CC. "La ley es una declaración de voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite."

Críticas:

1. Forma: la redacción parece indicar que la ley manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la CPol, y no por ser voluntad soberana.
2. Fondo: no señala las características específicas de la ley, no señala que debe ajustarse a ciertos principios de justicia. Sin embargo, el concepto social de justicia varía de un momento y lugar a otro. Los principios generales de justicia están en la Constitución, y si la ley los infringe, se puede alegar su inconstitucionalidad. *No da una idea del objeto de la ley, ni de lo que es en sí misma* (Alessandri), esto puede deberse a que la definición de ley de nuestro Código Civil es un concepto político de ley que atiende sobre todo

al acto de soberanía, a la legitimidad de su generación y no a su justificación material.

3.4 CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES.

Atendiendo a la clasificación tripartita del artículo 1 del Código Civil, las leyes pueden ser imperativas, prohibitivas y permisivas.

Crítica: toda ley imperativa es prohibitiva. No se justifica la tercera categoría, porque lo que no está prohibido, está permitido, por el principio de libertad.

a) Imperativas.

Son las que imponen la obligación de hacer algo (por ejemplo, artículos 1826, 378, 1801-2 CC) o el cumplimiento de un requisito (Estas últimas reciben el nombre de leyes "imperativas de requisitos", como sería para parte de la doctrina, los números 3 y 4 del artículo 1464 CC.).

No tienen una sanción genérica determinada. Para determinar su sanción hay que distinguir:

1. Disposiciones de interés general: son aquellas que dicen relación con el orden público y las buenas costumbres.
Orden público: conjunto de reglas esenciales para el mantenimiento de la sociedad.

Leyes que dicen relación con el orden público:

- a) Leyes de derecho público (art 1462 CC).
- b) Disposiciones de derecho privado que no pueden renunciarse por los particulares.
- c) Disposiciones que no pueden ser alteradas por los particulares. Ej. Derechos y obligaciones de los cónyuges.

Otros autores atienden a la naturaleza del vínculo entre la ley y el interés de la sociedad. Son de orden público:

- a) Leyes relacionadas con la organización política.
- b) Leyes relacionadas con la organización económica (protección de contratantes en inferioridad de condiciones, propiedad raíz, etc.)
- c) Leyes relacionadas con la organización social (familia, estado civil, etc.)
- d) Leyes relacionadas con la organización moral (juegos de azar, impedimentos dirimentes, etc.)

Buenas costumbres: normas morales conforme a la cuales se procede en forma concreta por la generalidad de las personas de una sociedad en una

época determinada.

La sanción a estas leyes imperativas de interés general es la nulidad absoluta si el acto tiene objeto o causa ilícita, o no cumple un requisito que la ley impone en atención a la naturaleza del acto. Es la nulidad relativa si es un requisito exigido en atención a la calidad de las partes.

Pero la disposición puede señalar una sanción distinta (inoponibilidad, limitación de medios probatorios, etc.)

Para Vodanovic, los requisitos del acto jurídico son de interés particular.

2. Disposiciones de interés particular: la sanción es la responsabilidad como norma general. Y si se trata del incumplimiento de una obligación contractual, puede haber una sanción adicional como la resolución o terminación. Pero la disposición puede establecer una sanción especial. Ej. Inoponibilidad.

b) Prohibitivas.

Contienen el mandato de no hacer algo y no lo permiten en ninguna circunstancia. 2 aspectos:

1. El acto no debe poder realizarse bajo ningún aspecto ni en ninguna circunstancia. Si la ley permite realizar el acto en determinadas condiciones, es imperativa de requisitos.
2. No es necesario que la ley emplee la expresión "se prohíbe". También se utilizan expresiones tales como "no vale" o "se tendrá por no escrita".

Por regla general, la sanción por la infracción de una ley prohibitiva es la nulidad (Art. 10, 1466 y 1682 CC). Pero hay excepciones, que se dan cuando la propia norma prohibitiva señala una sanción diferente.

Art. 10 CC. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.

Art. 1466 CC. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa; y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes.

c) Permisivas.

Confieren un derecho que queda entregado al arbitrio del titular. La sanción

consiste en darle al titular los medios para obtener el reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que acarree su desconocimiento.

Los particulares pueden renunciar los derechos que les confieren las leyes permisivas, siempre que miren al interés individual y no esté prohibida su renuncia (artículo 12).

3.5 AUTORIDAD DE LA LEY.

La autoridad de la ley se basa en la presunción de su conocimiento. Desde la fecha de su publicación la ley en el Diario Oficial se entiende conocida de todos y es obligatoria (Art. 7° CC) y nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que entró en vigencia (Art. 8° CC).

Art. 7 CC. La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria.

Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial.

Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia.

Art. 8 CC. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Pero la presunción del conocimiento de la ley no se ajusta a la realidad. Sólo tiene el alcance lógico de su obligatoriedad. Para Vodanovic, el Art. 8° no es una presunción, sino una ficción, es decir, la suposición de un hecho o situación distinta de la realidad, para lograr consecuencias jurídicas prácticas. Esta ficción se justifica para la obligatoriedad de la ley.

Es distinta la situación del error de derecho y la influencia que puede ejercer en los AJ. En esta materia, el Art. 1452 CC sigue la teoría clásica: el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. En ciertos casos, el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario (art. 706 CC). Pero hay casos en que el error de derecho es excusable, partiendo de la base de la buena fe. Ej. Matrimonio putativo.

En consecuencia, la presunción implica que la ignorancia jurídica de una persona no puede ser obstáculo para el cumplimiento de la ley, pero no señala las consecuencias del conocimiento o desconocimiento de las leyes.

Ciertos funcionarios, como los jueces, deben necesariamente saber el derecho,

su ignorancia es inexcusable. En esto se basa el hecho de que la ley no necesite ser probada: la obligación de su conocimiento por quien debe aplicarla.

Respecto de los particulares, el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento, pero pueden eventualmente estar protegidos si hay error de derecho y están de buena fe.

3.6 EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO.

La regla general es que las leyes produzcan efecto desde su promulgación y publicación en el diario oficial, hasta su derogación.

1. Vigencia inmediata:

El principio es que la ley inicia su vigencia en la fecha de su publicación.

Art. 6 CC. La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen.

Art. 7 CC. La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria.

Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial.

Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia.

En consecuencia la ley rige desde su promulgación y publicación.

La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto, y se efectúa mediante la dictación del decreto promulgatorio por el Presidente.

La publicación tiende a dar a conocer la ley y se realiza mediante la inserción de la ley en el Diario Oficial.

Existen dos excepciones al principio de vigencia inmediata:

a. Vacancia legal: se produce cuando una ley comienza a regir en época posterior a la de su publicación (artículo 7 inciso 3º) Esta situación se puede deber a que la ley establezca un plazo o condición para su propia entrada en vigencia.

Ejemplo de vacancia legal:

- El artículo final del Código Civil es un ejemplo de vacancia legal. El

decreto promulgatorio es de 14 de diciembre de 1855 y su artículo final establece: "*El presente código comenzará a regir desde el 1 de enero de 1857*". Es usual en Chile que las leyes que alteran fundamentalmente normas vigentes, contemplen una vacancia legal.

- En Chile hay, además, un caso de vacancia general: las leyes que modifican impuestos entran en vigencia el primer día del mes siguiente de su publicación (Código Tributario, artículo 3).

La vacancia legal de la ley nueva, produce como efecto reflejo la ultractividad de la ley antigua, puesto que ésta sigue rigiendo en el período entre la publicación de la ley nueva y su entrada en vigencia.

b. Retroactividad de la ley: ocurre cuando la ley señale una fecha de aplicación anterior a su vigencia.

La vigencia de la ley dura hasta su derogación: supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal, ya sea por su reemplazo o su eliminación. La derogación corresponde al legislador. La única facultad de los particulares es renunciar los derechos que la ley le confiere.

El legislador puede dictar leyes temporales, caso en el que la cesación de su eficacia (derogación de la ley) está predeterminada en la propia ley. Otras causas intrínsecas de cesación de eficacia de la ley es la realización del fin de esa ley (ej. Cuando se realiza la expropiación que la ley expropiatoria ordena) o el desaparecimiento de la institución jurídica que le servía de base (ej. Eliminación de algún régimen matrimonial).

La derogación puede ser:

1. Expresa: la nueva ley dice que deroga la antigua, individualizándola.
2. Tácita: la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la anterior. La incompatibilidad debe ser absoluta, pues quedara vigente todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Además, la primacía de la ley especial implica que la ley general posterior no deroga tácitamente la ley especial sobre la misma materia.

Art. 52 CC. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.

Art. 53 CC. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley

3. Orgánica: la nueva ley regula toda la materia reglamentada por una o más leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre disposiciones.

Una vez derogado el precepto legal, no revive sino por acto de legislación. Si se deroga la ley derogatoria, el precepto primitivo no revive.

2. Irretroactividad y retroactividad de la ley:

El principio establecido por el Código Civil es que la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Art. 9 inc. 1 CC.

Ello con la sola excepción de las leyes interpretativas, que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entienden incorporadas en las leyes que interpretan (y tiene efectivamente la fecha de vigencia de éstas), con la reserva de que no pueden afectar en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio (artículo 9 inc. 2 CC).

En consecuencia, la ley interpretativa es siempre y necesariamente retroactiva, con 2 limitaciones:

- a. Limitaciones constitucionales señaladas más adelante (penal y civil).
- b. Limitación del Art. 9º inc. 2º CC en cuanto a no afectar sentencias judiciales ejecutoriadas en tiempo intermedio.

Art. 9 CC. La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo.

Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.

Sin embargo, es importante entender que este principio se encuentra establecido en una norma de rango simplemente legal y no constitucional. Por lo tanto, a pesar de lo categórico de sus términos, obliga únicamente al juez y la aplicación que éste haga de la ley y no al legislador, quien podrá dictar normas retroactivas, con los límites que a continuación se señalarán.

Las limitaciones que tiene el legislador en la dictación de normas retroactivas están dadas por la Constitución, y son las siguientes:

- 1. En materia penal: Art. 19 N° 3 Constitución. Ante todo no pueden ser retroactivas las leyes penales por cuanto está consagrado específicamente por la Constitución el principio de irretroactividad. Así lo expresa el artículo 19 N° 3, cuyo inciso cuarto dispone *"nadie puede ser juzgado por comisiones*

especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta” (principio de la existencia previa del tribunal); y en su inciso séptimo que establece que *“ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”* (principio de la legalidad de la pena). En definitiva, la ley no puede ser retroactiva cuando es desfavorable al inculpado; la ley favorable es siempre retroactiva.

2. En materia civil: debe respetar las garantías constitucionales, especialmente el derecho de propiedad (Art. 19 N° 24 Constitución). Un derecho garantizado por la Constitución no puede ser dejado sin efecto por una ley posterior sino en los términos autorizados por la propia Constitución. En efecto, la retroactividad de una ley afecta, como se verá, derechos que una persona ya posee, de modo que si ese derecho afectado es establecido por la Constitución, la ley retroactiva será inconstitucional por contraria a la ley fundamental.

En circunstancias que el principio es la irretroactividad de la ley, en casos de existir retroactividad, esto es, el efecto excepcional de que una ley rija hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, es siempre de derecho estricto y por consiguiente debe ser establecido por el legislador.

Debido a que la retroactividad afecta la seguridad jurídica, debe ser expresa y su interpretación y aplicación deben ser restrictivas. Son normas de derecho estricto, y con éstos criterios deberá ser aplicada por el juez.

La retroactividad es una institución excepcional que afecta la seguridad jurídica. Altera el marco de previsiones que ha determinado nuestro actuar. Por lo tanto, a menos que el legislador lo haya establecido, y atendido el principio de irretroactividad de la ley, los jueces tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes de una manera que no resulte retroactiva.

Sin embargo, la experiencia mostró que formular el principio de irretroactividad era más sencillo que aplicarlo en la práctica en casos de cambio de legislación. Este hecho motivó al legislador, en los primeros años de vigencia del Código a dictar una ley que se encargará de regir estas materias, señalando al juez criterios para la aplicación del principio de irretroactividad.

La aplicación de esta ley, en todo caso, es inusual, pues la generalidad de las leyes que se dictan contienen reglas transitorias sobre su aplicación, que resuelven los conflictos temporales que pudiere desencadenar el cambio de legislación.

3.6.1 TEORÍAS PARA DETERMINAR SI UNA LEY ES RETROACTIVA.

El primer problema que suscita la aplicación del principio de irretroactividad es determinar cuándo una ley es retroactiva. Las principales doctrinas que han sido desarrolladas para definir un criterio son la de los derechos adquiridos y la

de las relaciones jurídicas

1. Teoría Clásica o de los derechos adquiridos y las meras expectativas.

Plantea que lo decisivo para definir la retroactividad son los derechos que establecen las leyes, a cuyo respecto las personas se pueden encontrar en dos situaciones

- (a) Derecho adquirido: el derecho subjetivo ya está incorporado al patrimonio de las personas (por un hecho o acto del hombre o ministerio de la ley) al dictarse una ley posterior, para lo cual se tienen que haber cumplido todos los antecedentes requeridos por la ley para su adquisición.
- (b) Mera expectativa: derecho no incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida legalmente. Es decir, el sujeto sólo tiene la esperanza de adquirir un derecho, pero aún no se han cumplido todos los requisitos que establece la ley para la adquisición.

Una ley es retroactiva si lesiona los derechos adquiridos. Por el contrario, si afecta meras expectativas no es retroactiva. La consecuencia normativa de esta distinción es que respecto de los derechos adquiridos rige la ley antigua y respecto de las meras expectativas rige la ley nueva. De ese modo queda, según la doctrina, garantizado el efecto no retroactivo de la ley.

La Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes contiene normas que, respectivamente, se refieren a las meras expectativas, que se ven afectadas por la ley nueva, y los derechos adquiridos, cuya pasada adquisición no se ve afectada.

Esta doctrina está concebida desde un punto de vista subjetivo. Lo que importa a la doctrina es que las posiciones jurídicas consolidadas (derechos subjetivos ya adquiridos) no sean afectadas por la ley posterior.

Críticas:

- La doctrina es extremadamente irretroactiva y provoca la ultractividad de la ley antigua.
- Es extremadamente individualista, quien haya consolidado una posición jurídica en la forma de un derecho subjetivo, tiene certeza que ésta permanecerá inamovible.
- Dado que tiene un carácter eminentemente patrimonial y subjetivo del concepto de derecho adquirido, no resuelve el problema con respecto a los derechos que no forman parte del patrimonio. Por ejemplo, los derechos que derivan de las relaciones de familia.

2. Teoría Moderna o de la situación jurídica de Roubier.

La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual

emanan deberes y derechos.

La situación jurídica, es un concepto más amplio y se refiere a la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica inmediata.

La situación jurídica tiene un momento en que se crea, en que produce efectos y en que se extingue. Distingue tres cuestiones fundamentales:

- En cuanto a la constitución de una situación jurídica: las relaciones jurídicas constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas condiciones para dicha constitución.
- En cuanto a los efectos de una situación jurídica: se rigen por la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva.
- En cuanto a la extinción de una situación jurídica: se rige por la ley vigente al momento en que esto ocurre.

Críticas:

- Toda relación privada lleva implícita alguna precariedad, al estar permanentemente sujeta a la eventual intervención del legislador.

3. Diferencia entre ambas doctrinas.

Ejemplo: Préstamo ha sido contratado en 2011 a una tasa de interés anual del 20%, se supone que en 2013 una nueva disposición establece como interés máximo una tasa de 12% y que el vencimiento de esta obligación es en 2015.

CONSTITUCIÓN [A]	[B]	EXTINCIÓN [C]
Inicio Julio 2011 20% interés anual	Mayo 2013 Nueva ley fija interés Máximo de 12% anual	Vencimiento Julio 2015

- Si la ley de 2013 fuera extremadamente retroactiva afectaría hechos pasados, es decir, incluso las cuotas de intereses ya pagados anteriores a mayo de 2013 estarían limitadas por el 12%.
- El grado intermedio de retroactividad coincide con el efecto estrictamente inmediato, esto es, sólo afecta los pagos correspondientes a cuotas que venzan después de la publicación de la nueva ley. Doctrina de la situación jurídica.
- El grado mayor de irretroactividad consiste en que la ley no afecte en modo alguno el contrato y se cumplan todos los efectos convenidos, aun bajo el imperio de la ley nueva. Doctrina de los derechos adquiridos.

3.6.2 LEY SOBRE EFECTO RETROACTIVO (LERL).

Nuestra legislación sigue, según las materias, criterios eclécticos: respecto de ciertas instituciones sigue la doctrina de los derechos adquiridos y respecto de otras se acerca a los principios de la doctrina de la situación jurídica. Las materias están planteadas con criterio casuístico y no teórico, considerando en cada caso los bienes jurídicos en juego.

1. Alcances sobre la Ley sobre Efecto Retroactivo:

- No está construida sistemáticamente, es más bien un listado de soluciones prácticas.
- Tiene un carácter supletorio, rige respecto de leyes que no regulan por sí mismas sus efectos en el tiempo.
- El nombre de la ley es equívoco pues sus normas regulan el efecto irretroactivo.
- La doctrina chilena ha considerado que la ley está construida sobre la base de la doctrina de los derechos adquiridos pero diversas normas específicas establecen criterios que no son enteramente interpretables bajo esta doctrina.
- En materia de contratos rige la teoría de los derechos adquiridos sin restricciones. No se acepta que un derecho adquirido en virtud de la celebración de un contrato se pierda o modifique por la dictación de una nueva ley. Ello se explica por el lugar prevalente que tiene en todo contrato la previsión del futuro que efectúa cada parte.
- El principio de los derechos adquiridos se consagra principalmente en:

Art. 7° inciso 1 LERL: <i>las meras expectativas no constituyen derecho.</i> Art. 8° LERL: <i>un derecho ya adquirido bajo la antigua ley, como es la capacidad de ejercicio, se conserva bajo el imperio de una ley nueva, aunque ésta establezca requisitos adicionales para su adquisición.</i>
--

2. Materias que trata la Ley sobre efecto retroactivo:

1) ESTADO CIVIL (ARTS. 2° A 7° LERL):

- El estado civil adquirido conforme a la ley vigente al tiempo de su constitución subsiste aunque ésta pierda su fuerza. Esta solución no se explica por la Teoría Clásica, porque el estado civil no es un derecho patrimonial. Pero sí por la Teoría Moderna, por cuanto el estado civil adquirido sería una situación jurídica constituida.
- Las leyes que establecen nuevas o diferentes condiciones para la adquisición del estado civil se aplican desde que comienzan a regir. Según la Teoría Clásica, la adquisición del estado civil sería una mera expectativa, por lo que la aplicación de la nueva ley no lo sería con efecto retroactivo. Según la

Teoría Moderna, debe aplicarse la nueva ley porque la situación jurídica no se ha constituido.

- Los derechos y obligaciones anexos al estado civil se subordinan a la nueva ley.
- Prevención: Con la entrada en vigencia de la Ley Nº19.585, que tuvo como objetivo fundamental "sustituir el régimen de filiación del Código Civil y su reemplazo por otro que estableciera un trato igualitario para todos los hijos" y que se consagró expresamente en el artículo 33 del CC, se consagró en Chile un solo estado civil derivado de la filiación, sea matrimonial o no matrimonial: el estado civil de hijo. Ya no existen hijos legítimos, naturales o simplemente ilegítimos.

2) CAPACIDAD (ARTS. 7º INC. 2º, Y 8º LERL):

- La capacidad de goce queda sujeta a la nueva ley. La LERL la considera como una facultad legal no ejercitada.
- La capacidad de ejercicio obtenida no se pierde aunque la nueva ley exija otras condiciones para ella. Es decir, la considera un derecho adquirido.
- El ejercicio y continuación de la capacidad se rigen por la ley nueva.
- La doctrina establece que en materia de capacidad de ejercicio la LERL se aparta de la Teoría Clásica que considera a esta capacidad como una facultad legal no ejercitada.

3) DERECHOS REALES (ARTS. 12 Y 15 A 17 LERL):

- El derecho real adquirido bajo una ley subsiste bajo la ley posterior.
- Sus goces, cargas y extinción se rigen por la nueva.
- El art. 12 ha sido objeto de innumerables críticas. Este artículo consagra el principio del derecho adquirido con respecto al derecho real y, por tanto, es irretroactivo. Pero en cuanto al goce y cargas del derecho, se les asimila a facultades legales no ejercitadas, lo que podría transformar a la ley en retroactiva, porque a través de ello se podrían modificar las facultades a tal punto que se podría, en la práctica, privar al derecho de ellas, y nos encontraríamos ante un derecho sin facultades, sin contenido.

4) POSESIÓN (ART. 13 LERL):

- El artículo 13 de la LERL dispone que "la posesión constituida bajo una ley anterior no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o con los requisitos señalados en ésta".
- Sobre el real alcance de esta norma existen dos posiciones doctrinarias:
 - a) Para algunos, siguiendo la razón del art.12 LERL, las reglas serían las siguientes:
Posesión constituida. Es un derecho adquirido, y, por lo tanto, la nueva ley no lo afectaría.
Efectos. Se verían sujetos a la nueva ley, pues se trataría de facultades legales no ejercitadas (derechos y obligaciones).

b) La otra posición entiende que debe aplicarse la ley nueva, tanto respecto de los efectos como de los requisitos para ser poseedor. El fundamento de esto está en que la posesión es un hecho que tiene cada poseedor, no pudiendo calificarse como un derecho adquirido. Sólo tendrá el carácter de poseedor aquel que cumpla con los requisitos que impone la nueva ley: sería tan solo una mera expectativa)

- Debemos hacer presente que en esta situación, la irretroactividad de las leyes posesorias es sólo una ilusión. Ello, porque si la nueva ley establece mayores exigencias para conservar o retener la posesión, el que ya la había adquirido, para no perderla, debería ajustarse al mandato de la nueva ley, lo que confirmaría que las leyes sobre posesión serían en cierta forma retroactivas.

5) Derechos condicionales (Art. 14 LERL): el plazo para considerarla fallida es el de la ley antigua, a menos que exceda el establecido por la nueva a contar desde su vigencia.

6) SUCESIONES (ARTS. 19 A 21 LERL):

- Las solemnidades del testamento se rigen por la ley vigente a la época de su otorgamiento.
- Las disposiciones testamentarias, incapacidad o indignidad de los herederos, desheredaciones, etc. se rigen por la nueva ley (ley vigente al momento de la muerte).
- No dice nada de los requisitos internos (capacidad y voluntad del testador), pero la mayoría opina que se rigen por la ley vigente al tiempo de otorgarse el testamento.
- En la sucesión intestada, la representación se rige por la ley bajo la cual se abre la sucesión.
- La adjudicación o partición de la herencia se rige por la ley vigente al tiempo de su delación.

7) CONTRATOS (ARTS. 22 Y 23 LERL):

- En todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Las leyes vigentes al tiempo de la celebración determinan tanto los requisitos de validez, de fondo y de forma, como el alcance de los derechos y obligaciones a que el contrato da lugar. No se plantea un problema de retroactividad si no de supervivencia de la ley.

Excepciones:

1. Leyes concernientes a reclamar en juicio los derechos que resultan de ellos.
 2. Leyes que señalan penas para el caso de incumplimiento.
- Los contratos se pueden probar por los medios vigentes al tiempo de su celebración, pero la forma de rendir la prueba se rige por la nueva ley.

8) PROCEDIMIENTO JUDICIAL (ARTS. 22 N°1 Y 24 LERL):

- Las leyes procesales rigen in actum.
- Los términos que han empezado a correr y las actuaciones ya iniciadas se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

9) PRESCRIPCIÓN (ARTS. 25 Y 26 LERL):

- El prescribiente puede escoger entre el plazo de la ley antigua o la nueva, pero si elige la nueva, el plazo comienza a correr desde que ella empieza a regir.
- Si una ley declara algo imprescriptible, no puede adquirirse bajo su vigencia.

3.7 EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO A LAS PERSONAS.

El principio que rige en cuanto a los efectos de la ley respecto de las personas es el de la territorialidad de la ley chilena.

Art. 14 CC. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.

En consecuencia, el ámbito personal de aplicación de la ley chilena se extiende a todos los habitantes; no sólo a los domiciliados sino también a los residentes e incluso a los transeúntes.

Son chilenos:

Art. 56 CC. Son chilenos los que la constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros.

Art. 57 CC. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.

Art. 58 CC. Las personas se dividen, además, en domiciliadas y transeúntes.

Por lo tanto, chilenos y extranjeros están sometidos a la ley chilena y se asimilan en materia de derechos civiles, lo que tiene excepciones.

(1) Ante todo, de acuerdo a los principios de derecho internacional, la ley chilena reconoce a los agentes diplomáticos y a los estados y organizaciones internacionales inmunidad de jurisdicción, en virtud de lo cual no pueden ser llevados a tribunales chilenos.

(2) Por otro lado, en diversas leyes se distingue entre chilenos y extranjeros respecto de ciertos derechos que obedecen a principios de reciprocidad:

- i. La propia Constitución reconoce la ciudadanía sólo a los nacionales. Los derechos políticos están reservados, por regla general, exclusivamente para ellos.
- ii. El DL 1939 de 1977 impone restricciones a los extranjeros para la adquisición de bienes raíces en zonas fronterizas.
- iii. Hay ciertas actividades que se encuentran reservadas para los nacionales, como la pesca, la navegación respecto a puntos al interior del país, las telecomunicaciones, etc.
- iv. En ocasiones la ley impone ciertas limitaciones a los extranjeros no domiciliados en Chile (transeúntes, de acuerdo con el artículo 58) respecto al ejercicio de ciertos derechos. Así:
 - El artículo 497 les impide ejercer una tutela o curatela.
 - El artículo 1012 no les permite ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile.

3.8 EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TERRITORIO.

El territorio del Estado está delimitado por sus fronteras, pero la autoridad del Estado comprende todo el territorio terrestre, con su espacio aéreo y subsuelo, el mar territorial (definido por el artículo 593) y la zona económica exclusiva (definida por el artículo 596)

- ❖ El principio general es nuestro derecho es la territorialidad de la ley (aplicación de la ley dentro de los límites del territorio del Estado); la extraterritorialidad es excepcional.

La territorialidad está establecida en los Arts. 14 y 16 inc. 1º CC.

Art. 14 CC. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.

Art. 16 inciso 1 CC. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.

En consecuencia, la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, y los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena.

Art. 17 CC. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento.

La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.

Del Art. 17 CC se desprende que la forma de los actos otorgados en Chile se rige por la ley chilena.

❖ Extraterritorialidad de la ley chilena.

(a) Aplicación de la ley extranjera en Chile.

a.1 Son válidas en Chile las estipulaciones de los contratos otorgados válidamente en el extranjero (Art. 16 inc. 2° CC), es decir, tendrá aplicación la ley extranjera en Chile por aplicación del principio de la "ley del contrato". Pero esto está limitado por el Art. 16 inc. 3° CC, que dice que los efectos de estos contratos, para cumplirse en Chile, se sujetan a la ley chilena.

Art. 16 inc. 1 CC. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.

Inc. 2. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño.

Inc. 3. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas.

a.2 La sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre, por lo tanto se regirá por la ley extranjera si se abre en el extranjero (Art. 955 inc. 2° CC).

Art. 955 CC. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados.

Inc. 2. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvo las excepciones legales.

Pero esto tiene dos excepciones:

Art. 16 inc. 1. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.

Art. 998: En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a Título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno.

Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero.

Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero.

(b) Aplicación de la ley chilena en el extranjero:

Art. 15 CC: A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero.

Esta disposición es doblemente excepcional:

1. En cuanto a las personas a quienes afecta: sólo a los chilenos.
2. En cuanto a las leyes a que queda sujeto el chileno: sólo las que taxativamente señala, que son las siguientes:
 - a. Las que se refieren al estado de las personas, es decir, a la constitución, derechos y obligaciones inherentes al Estado Civil y a su terminación. La excepción a esta norma viene dada por los efectos que emanan del estado civil, ya que los derechos y obligaciones solo regirán respecto a cónyuges y parientes chilenos.
 - b. La capacidad del chileno en el extranjero queda afecta a la ley chilena, solo en cuanto vaya a ejecutar un acto que haya de tener efecto en Chile.

c) Leyes relativas a los actos:

Para la ley chilena, el problema es el relativo al acto celebrado en el extranjero y que produce efectos en Chile. Hay que distinguir:

a. Requisitos externos:

De acuerdo con el principio *locus regit actum*, se rigen por la ley del país en que el acto se realiza. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que se otorgan (Art. 17 CC), pero el principio se aplica también a los instrumentos privados (16 inc. 2º CC).

Pero hay excepciones. Ejemplos.

- Si la ley chilena exige que se otorgue instrumento público, no tiene valor la escritura privada otorgada en el extranjero, aunque tenga pleno valor en el país en que se otorgó (Art. 18 CC).

Art. 18 CC. En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

- Asimismo, sólo tiene valor en Chile el testamento otorgado en el extranjero si lo ha sido por escrito; el testamento verbal no tiene validez, aunque la tenga en el país en que se otorgó (Art. 1027 CC).

Art. 1027 CC. Valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria.

b. Requisitos internos:

En general, la ley del país en que se otorgó el acto rige sus requisitos internos, o sea, la capacidad y voluntad o consentimiento de los que lo otorgan, y el objeto y la causa del acto, con la limitación del Art. 15 N° 1 CC (en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile).

Art. 15 CC. A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero.

1. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile;
2. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.

c. Efectos:

Los efectos, es decir, los derechos y obligaciones que emanan del acto, quedan sujetos a la ley chilena.

3.9 INTERPRETACIÓN DE LA LEY.

Interpretación de la ley: fijar su verdadero sentido y alcance (elemento abstracto), incluyendo la actividad indispensable para aplicar el derecho (elemento concreto).

Según si la legislación establece o no normas de interpretación, ésta se denomina reglada o no reglada. El CC ha adoptado la interpretación reglada, estableciendo normas de interpretación de la ley (principalmente Arts. 19 a 24 CC).

Según de quien emane la interpretación, se divide en interpretación por vía de doctrina o privada, y por vía de autoridad.

(1) Interpretación doctrinal.

La realizan los jurisconsultos, abogados y otros. No tiene fuerza obligatoria; su importancia depende del prestigio de la persona de quien emana.

Hay diversos métodos de interpretación:

1. Escuela de la exégesis en derecho civil (comentaristas del Código de Napoleón, Laurent): se caracteriza por el culto del texto de la ley, el predominio de la búsqueda de la intención del legislador (infalible), y el respeto a las autoridades y los precedentes. La ley es la única fuente de las decisiones jurídicas. Este criterio impide la evolución y progreso del derecho.

2. Teoría de la libre investigación científica (Geny): método libre para llegar a las fuentes reales de las normas, que contienen un elemento racional (noción del derecho) y uno experimental (aspiración a la armonía colectiva). La interpretación procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley. *Alessandri: el intérprete debe tomar como criterio general de orientación la idea de justicia y fundarse en la naturaleza real de las cosas.*

3. Escuela histórica del derecho (Savigny). El derecho es concebido como la expresión práctica de la vida o el espíritu de un pueblo. De esta manera, el derecho positivo y su aplicación práctica no pueden apartarse de las costumbres del pueblo, que expresan su espíritu de manera más directa.

4. Escuela del derecho libre (Kantorowicz): frente al derecho estatal hay un derecho libre, *que* surge espontáneamente de la conciencia social y espontáneamente también es aplicado (Alessandri). Estos pueden o no coincidir. La jurisprudencia no puede sólo basarse en el primero. Alessandri: el intérprete debe prescindir de la ley cuando su texto no es claro y se convence de que el legislador no habría resuelto el conflicto en el sentido que lo hace la ley.

5. Doctrina teleológica (Ihering): busca la finalidad práctica de la ley. A partir de esta doctrina se desarrolla el método de la jurisprudencia de los intereses: el intérprete debe decidir el conflicto de intereses dando preeminencia a los que han sido preferidos por el legislador.

6. Teoría del derecho puro (Kelsen): todo derecho deriva de la voluntad del Estado y no hay más derechos que el derecho positivo.

(2) Interpretación por vía de autoridad.

Es la que emana del legislador o del juez, pero existen otros organismos autorizados para interpretar las leyes relativas a la función que se les encomienda.

i. Interpretación por el legislador.

La interpretación legal, llamada también auténtica, es la que realiza el legislador, y tiene fuerza obligatoria general (Art. 3º CC). No está sujeta a reglamentación alguna.

Art. 3. Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.

La interpretación legal se efectúa por medio de la ley interpretativa. Como la ley interpretativa es necesariamente retroactiva, la interpretación legal tiene un límite:

- a. no puede modificar los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
- b. Tampoco puede transgredir las garantías constitucionales.

ii. Interpretación judicial.

La interpretación judicial es la que realiza el juez en las causas sometidas a su conocimiento, y tiene fuerza obligatoria relativa exclusivamente al litigio en cuestión. Debe sujetarse a las normas de interpretación del CC.

- **Integración de la ley.**

Frente a un caso específico, el juez puede encontrarse en la situación de que no exista una norma precisa del ordenamiento positivo que resuelva la materia. Esta situación se denomina laguna legal.

Los Arts. 76 inciso 2º de la Constitución y 10 COT establecen el principio de inexcusabilidad: reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda.

Asimismo, el Art. 170 N° 5 CPC establece dentro de los requisitos de las sentencias, la enunciación de los principios de equidad en que se funda.

Estas disposiciones establecen expresamente la facultad de integración de los jueces, los que deben fallar aun frente a una falta de ley (laguna legal). Los vacíos pueden existir en la ley, pero no en el derecho.

La analogía y el espíritu general de la legislación a que se refiere el Art. 24 CC

pueden sólo servir al juez para establecer la razón de equidad que sirve de fundamento al fallo.

- **Finalidad de la interpretación.**

Es buscar el sentido de la ley.

Art. 19 inc. 1º CC. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.

Esto no significa la primacía de la aplicación de la ley de acuerdo al tenor literal. La disposición se refiere a la claridad del sentido de la ley, no del tenor literal. El tenor literal se aplica en cuanto refleje ese sentido.

El punto de partida de la interpretación es el elemento literal, pero no se reduce a un análisis gramatical.

El que sea necesario determinar, en forma previa, si el sentido de la ley es claro, significa que siempre debe realizarse un proceso interpretativo.

Hay leyes claras en su texto abstracto, pero que se vuelven oscuras frente a situaciones concretas.

Alessandri: el sentido de la ley es claro no sólo cuando el precepto está redactado en términos que no provoquen dudas; también es necesario que no haya otro precepto que lo contradiga.

- **Criterios de interpretación.**

1. Histórico o subjetivo: trata de reconstruir el pensamiento o voluntad del legislador.

2. Normativo u objetivo: sostiene que la ley tiene una significación propia independiente del pensamiento de sus autores.

Los autores modernos desechan el subjetivo por 3 razones:

- a) No es posible determinar una voluntad subjetiva del legislador.
- b) Si lo fuera, esa voluntad carece de sentido frente a la evolución.
- c) La ley es la voluntad del Estado que se manifiesta por la ley misma, no por la opinión de los que participaron en su formulación.

El CC es terminante en cuanto a que el sentido objetivo de la ley debe buscarse en ella misma. No hay norma que permita buscar una supuesta voluntad del legislador. La historia de la ley sirve sólo para buscar el sentido objetivo de la misma.

- **Elementos de interpretación.**

El legislador establece un sistema de interpretación reglado para el juez. Los elementos que guían la interpretación del juez están establecidos en los artículos 19 a 24 del Código Civil. Estos elementos no deben entenderse como una sucesión jerárquica, donde algunos principios tienen, a priori, más peso que los demás. Más bien, el intérprete debe recurrir a cada uno de estos elementos para fijar el sentido de la ley.

En este sentido, es necesario notar que el artículo 19 no ordena al intérprete a darle una primacía absoluta al elemento gramatical. Más bien, le prohíbe desatender el tenor literal si es que el sentido de la ley es claro. Pero, como ya vimos, la determinación de la claridad del sentido de la ley respecto a un caso concreto es, a su vez, el producto de un ejercicio interpretativo. Y, para dicho ejercicio interpretativo, el juez debe recurrir a todos los elementos que la ley dispone.

1. Elemento gramatical (Art. 19 inc. 1º CC): análisis de la semántica y sintaxis del precepto. Este elemento se descompone en tres reglas:

a) Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio (Art. 20 CC): Antiguamente los tribunales buscaban dicho sentido en el diccionario de la RAE; hoy lo buscan en el uso que se les da en el medio en que se las emplea.⁷

b) Las palabras que el legislador ha definido expresamente para ciertas materias se les dará su significado legal (Art. 20 CC).⁸

c) Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan esa ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en un sentido diverso (Art. 21 CC).⁹

Art. 20 CC. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Art. 21 CC. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

⁷ Ejemplo: El art. 906 establece, a propósito de las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria, que el poseedor de mala fe es responsable de los "deterioros". No hay definición legal de deterioro, pero sabemos que se refiere a cualquier detrimento o daño, pues ese es su sentido natural y obvio.

⁸ Ejemplo: "Tradición", art. 670 CC; "Auto", art. 158 CPC.

⁹ Ejemplo: el art. 1447 CC establece que los dementes son incapaces absolutos. ¿Qué significa ser un demente? Según el uso de quienes practican las ciencias médicas y psiquiátricas, demente es aquel privado total o parcialmente de sus facultades mentales.

2. Elemento histórico (Art. 19 inc. 2º parte final CC): se refiere a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Sirve para fijar su intención o espíritu (de la ley, no del legislador), es decir, sus objetivos.

Art. 19 CC. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento

Alessandri: este elemento tiene por objeto la indagación del estado del derecho existente sobre la materia a la época de la confección de la ley y el estudio de los antecedentes que tomó en cuenta el legislador antes de dictarla.

“Expresión oscura”: no puede entenderse absolutamente (ininteligible) o se presta a más de una interpretación (ambigua).

3. Elemento lógico

(Art. 19 inc. 2º y 22 inc. 1º CC): concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley, pues es natural que éstas no sean contradictorias y exista entre ellas una unidad conceptual y de criterio. Alessandri: este elemento se dirige a investigar la ratio legis (propósito perseguido por la ley, la razón que la justifica) y la occasio legis (circunstancias particulares que determinaron su dictación).

Art. 22 inciso 1 CC. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4. Elemento sistemático

(Art. 22 inc. 2º CC): correspondencia de la legislación que se busca más allá de la propia ley interpretada, analizando otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

Alessandri: este elemento se basa en la interna conexión que enlaza a todas las instituciones jurídicas y normas en una gran unidad.

Art. 22 inciso 2 CC. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

5. Espíritu general de la legislación y equidad natural (Art. 24 CC): no son sólo elementos supletorios. El espíritu general de la legislación se encuentra implícito en el elemento sistemático, y la equidad no puede estar ausente en

ningún criterio de interpretación. Pero el juez no puede dictar una resolución basada únicamente en la equidad, a eso se refiere la primera frase del art. 24 CC.

Art. 24 CC. En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.

Espíritu general de la legislación: el conjunto de principios que sirven de base a las distintas leyes y que le dan unidad a la legislación.

Equidad: Lo que es justo según las circunstancias particulares del caso concreto.

Además, el CC da las siguientes reglas: (Arts. 4, 13 y 23 CC).

Art. 4 CC. Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código.

Art. 13 CC. Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición.

Art. 23 CC. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes.

Procedimientos de interpretación.

1. Interpretación extensiva: se aplica a una situación particular normas que fijan reglas generales, o se deduce una norma generalizada de los ejemplos no taxativos que contienen las disposiciones.

Alessandri: implica comprobar que el precepto expresa menos de lo que fue querido por el pensamiento legislativo. La ley se aplica a más número de casos que los comprendidos en el tenor literal.

El argumento analógico supone una similitud en las situaciones (tanto en el hecho como en el fin jurídico); de acuerdo con él, los hechos que tienen igual valor jurídico implican las mismas consecuencias jurídicas. Se puede emplear analogía como elemento de interpretación o como base de integración.

2. Interpretación restrictiva: el precepto no puede aplicarse extensivamente ni servir de base para una interpretación analógica. Son de interpretación

restrictiva:

- a) Las leyes penales, incluyendo todo tipo de sanciones. Las leyes tributarias no permiten interpretación extensiva.
- b) Las leyes de excepción, los preceptos prohibitivos, los que establecen incapacidades y prohibiciones, etc.

Alessandri: implica comprobar que el precepto expresa más de lo que fue querido por el pensamiento legislativo. La aplicación de la ley no se extiende a un caso que, según el tenor literal, parece estar comprendido en ella.

Para Alessandri hay un tercer tipo: interpretación declarativa. Implica reconocer que la fórmula o los términos literales coinciden exactamente con el pensamiento legislativo, es decir, lo expresan con fidelidad y acierto. La ley se aplica a todos los casos que expresan sus términos, ni a más ni a menos.

Los aforismos son formas que toman la argumentación o lógica jurídicas. Alessandri: son reglas prácticas de interpretación, que no tienen valor absoluto ni deben ser empleados de modo exclusivo. Ejemplos:

- Argumento *a generale sensu*: donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir.
- Argumento *a fortiori*: son dos: *A maiore ad minus* (quien puede lo más, puede lo menos) y *a maiore ad maius* (a quien le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más).
- Argumento *a contrario sensu*: incluida una cosa se entienden excluidas las demás.
- Alessandri *agrega el argumento a pari*: argumento de analogía (donde existe la misma razón debe existir la misma disposición).

CAPÍTULO 4. LA COSTUMBRE.

4.1 LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO.

En el fondo, la costumbre es históricamente anterior y determina el origen de la ley; la ley la recoge, le da firmeza, claridad y fuerza obligatoria.

Tanto la costumbre como los principios se originan sin la intervención de un acto expreso de voluntad.

En toda sociedad se practican usos sociales que son respetados en forma espontánea, sin interrogarse acerca de las razones que justifican su observancia.

No todo uso (repetición externa de una práctica social) constituye en sí mismo una norma. El concepto de costumbre está reservado para esa categoría específica de usos de carácter normativo, los que comportan el deber de observar cierta conducta.

De aquí que se pueda definir a la costumbre como un uso normativo, en la medida que importa:

- i. La repetición constante y permanente de una determinada práctica social (aspecto externo propio del uso).
- ii. Un elemento de carácter interno (normativo) que transforma esa práctica en deber.

Definición de Vodanovic: observancia constante y uniforme de una regla de conducta, realizada por la generalidad o gran mayoría de los miembros de una comunidad, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.

4.2 REQUISITOS DE LA COSTUMBRE.

Requisitos de la costumbre para tener jurídicamente el carácter de tal:

1. Debe ser un uso social de carácter general.
2. Debe ser uniforme.
3. Debe ser constante.
4. Debe tener una cierta duración en el tiempo.
5. Debe tener un substrato jurídico (intención de obrar jurídicamente: elemento subjetivo o interno).

El CC no define costumbre. El CCom dice que las costumbres mercantiles son tales cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos,

generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por el largo espacio de tiempo (Art. 4 CCom).

4.3 EFICACIA DE LA COSTUMBRE.

En la tradición jurídica moderna, producto de la influencia del racionalismo, de la tecnificación del Estado y de los principios jurídicos de la soberanía, la costumbre ha quedado subordinada a la ley. La fuente dominante ha pasado a ser la ley positiva, entendiéndose que a ella corresponde determinar el valor de la costumbre.

4.4 TIPOS DE COSTUMBRE Y VALOR.

En la tradición jurídica chilena se ha definido el valor de la costumbre en atención a su relación con la ley.

(a) Según ley (secundum legem):

Es aquélla a la que el propio legislador hace referencia, ordenando que se tenga por derecho. Consisten en maneras uniformes de interpretar y aplicar la ley.

Regla: De acuerdo con la doctrina de la supremacía de la ley, la costumbre tiene una fuerza delegada por el legislador:

Art. 2 CC. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.

La doctrina nacional ha entendido, según esta norma, que la costumbre tiene una importancia secundaria, referida sólo a los casos en que la ley la invoca.

Reglas específicas de remisión:

Dentro de las pocas referencias que hace el Código a la costumbre, algunas dicen relación a ciertos contratos en particular, pero en otros casos se trata de materias generales a todo el derecho privado, en normas por completo críticas.

Gran parte de las remisiones específicas a la costumbre son hechas por el Código a propósito del contrato de arrendamiento.

- El uso que debe darse a la cosa arrendada, a falta de convención, se entenderá que es el que resulte de la naturaleza de la cosa, o de las circunstancias del contrato, o de la costumbre del país (art. 1938).
- Las reparaciones locativas (aquellas que son de cargo del arrendatario) son

definidas en función de la costumbre del país (art. 1940).

- Los períodos de pago de la renta son determinados por la costumbre, a falta de estipulación de las partes (art. 1944).
- La duración y término del contrato también se definen subsidiariamente de acuerdo con la costumbre (art. 1951). En el contrato de mandato la costumbre determina, a falta de convención, la remuneración del mandatario (art. 2158).

Reglas generales de remisión:

Al margen de estas reglas precisas en que la ley invoca a la costumbre para efectos específicos, existen normas que contienen remisiones generales a la costumbre, que se encuentran ubicadas en el centro del derecho de obligaciones. A continuación nos referiremos a las principales.

1. La costumbre determina el contenido de las obligaciones, y en particular del contrato.

En virtud del artículo 1545 del Código Civil los contratos tienen obligatoriedad de ley para los contratantes. A su vez el artículo 1546 señala que:

Art. 1546 CC. "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella".

Esta norma dispone que las partes de un contrato están obligadas más allá de la literalidad del pacto. Además de lo expresamente convenido, las partes están obligadas a la observancia de las otras normas dispositivas emanadas de la ley o de la costumbre. La referencia a la naturaleza de la relación es también una referencia a la costumbre: lo que constituye la naturaleza de la relación es su entidad económica, en la forma que espontáneamente es entendida en las prácticas sociales, conforme puede deducirse de las expectativas recíprocas e implícitas de las partes.

A su vez, el art. 1444 dice que:

Art. 1444 CC. En todo contrato cabe distinguir las cosas que le son esenciales, las de su naturaleza y las puramente accidentales. Son elementos de la naturaleza de un contrato aquellos que, sin ser esenciales, se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula especial.

La costumbre es elemento de la naturaleza de los contratos y por consiguiente completa el contenido del contrato, precisando los derechos y obligaciones de las partes, cuando éstos no han pactado una regla diversa.

Por su parte, también respecto a los contratos, el artículo 1563 inciso 2 complementa al 1546 al establecer que:

Art. 1563 incº 2 CC. "Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen".

De esta manera los usos contractuales forman parte de los contratos sin necesidad de expresarlos. Esta norma, ubicada entre las que establecen el régimen de interpretación de los contratos, asigna a la costumbre un rol implícito en la interpretación de los contratos. En la práctica comercial, especialmente internacional, recibe esta regla particular aplicación.

En caso alguno la costumbre se sustituye en estas materias a lo que hayan acordado las partes de un contrato. Estas reglas, respetando la autonomía privada, sólo expresan la realidad de que el orden de contratos se encuentra inmerso en prácticas sociales.

2. La costumbre define los límites de la autonomía privada.

La costumbre es también decisiva al momento de definir la ilicitud de los actos jurídicos (art. 1461 inc. final y art. 1467). La autonomía privada o libertad contractual tiene como límite las normas de orden público y las buenas costumbres. Estas últimas se refieren a las convicciones espontáneas acerca de los límites de lo lícito. Este límite está establecido por nociones espontáneas, compartidas por el grupo social, que varían en el tiempo.

Así, por ejemplo, las percepciones acerca de lo jurídicamente ilícito han tendido a desplazarse desde una moral referida a materias que recientemente quedan radicadas en el juicio moral de cada cual, protegido por una norma que incluso cautela la intimidad, hacia la idea de respeto recíproco. El respeto recíproco, (esto es, la ilicitud del abuso), son considerados atentados contra las buenas costumbres, más que las cuestiones tradicionales de moral sexual, cada vez más radicadas en la esfera íntima y privada de las personas. Así, la evolución de las costumbres desplaza los límites de la licitud contractual: lo contrario a las buenas costumbres no es hoy lo mismo que a la dictación del Código.

En suma, la importancia relativa de la costumbre según ley es muy considerable y excede en mucho el valor que le ha reconocido la doctrina civil chilena hasta ahora. Su importancia en el campo de las obligaciones es de tal amplitud que difícilmente pueda decirse que se encuentra subordinada a la

ley.

Para cierto sector de la doctrina, la costumbre, además, determinaría el estándar de cuidado debido en las relaciones privadas y, por tanto, tendría relevancia en materia de responsabilidad.

Cuando una persona deja de cumplir por su culpa un deber contractual o extracontractual, debe indemnizar los perjuicios provocados. El criterio para dar lugar a la responsabilidad es haber actuado culpablemente (referencias: art. 1547, por el cual se responde en materia de contratos en distintos grados de culpa; arts. 2284 y 2314, en materia de responsabilidad extracontractual). También en este punto tan crucial, el legislador ha recurrido a la costumbre para conceptualizar la idea de culpa. La culpa está definida en torno a estándares de cuidado. Así, actúa con:

- Culpa grave quien no maneja "los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios".
- Culpa leve si se falta a "aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios".
- Culpa levísima si se falta a "aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en sus negocios importantes" (art. 44).

Puede apreciarse que la culpa, que es antecedente de la responsabilidad contractual y extracontractual, se basa en apreciaciones acerca de lo que puede esperarse, según los casos, de un hombre negligente, de un hombre común (buen padre de familia) o de un hombre diligente. Rara vez es la ley la que define el cuidado debido en las relaciones privadas (lo hace, por ejemplo, en materia de tránsito), de modo que lo usual es que el patrón de conducta debida esté determinado con arreglo a los estándares sociales de conducta.

Así, si bien no se invoca en forma expresa a la costumbre, la referencia a modelos sociales de personas (buen padre de familia; hombre diligente; hombre negligente) constituyen conceptos normativos extralegales, que hacen referencia implícita a lo que es tenido socialmente por correcto. Y ello puede interpretarse como una referencia a las prácticas sociales tenidas por obligatorias, esto es, a la costumbre.

(b) En silencio de ley (praeter legem) o fuera de ley:

Es aquélla que actúa en caso que la ley no haya regulado ciertas materias, y a falta de toda invocación que la haga obligatoria. En este sentido complementa el derecho escrito.

Especialmente en materia comercial, la costumbre tiene una función integradora del derecho, completando los vacíos de la ley. Los proyectos

originales del Código Civil aceptaban la costumbre en silencio de la ley, pero finalmente fue excluida, quedando sólo aceptada la costumbre según ley (art. 2).

Art. 2. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.

En materia civil, entonces, la costumbre no es técnicamente una fuente formal autónoma. La costumbre *praeter legem* no tiene valor de fuente formal en el Derecho Civil.

Entretanto, en materia comercial expresamente se le otorga validez a la costumbre en silencio de ley:

Art. 4 C. Com. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que la constituyen son:

- uniformes,
- públicos,
- generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad,
- y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los Juzgados de Comercio" (Código de Comercio).

Esta norma acepta la tradición mercantil que asigna a la costumbre gran relevancia como fuente.

(c) Contra ley (contra legem):

Es aquélla que se opone a un precepto legal. Lo deja sin aplicación o lo infringe.

En un estado de derecho legislado, como el moderno, la costumbre contra ley carece de valor.

Ello desde luego que vale frente a normas legales de orden público, que claramente prevalecen sobre la costumbre.

Sin embargo, en caso de conflictos de la costumbre con leyes dispositivas, ésta puede tener valor supletorio incluso contra *legem*. Si la costumbre interpreta la voluntad tácita o presunta de las partes mejor que una ley dispositiva, el juez debería fallar según la costumbre. Ello es consecuencia de que las normas legales supletivas integran el contrato reemplazando la voluntad común de las partes, de modo que si una costumbre la interpreta mejor deberá estarse a ella (arts. 1560, 1563, 1546).

Art. 1560 CC. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

Art. 1563 CC. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.

Art. 1546 CC. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.

Por otra parte, la costumbre jamás deroga formalmente la ley. Como dice un moderno texto de derecho civil francés: "el desuso mata las leyes, pero mejor no lo digamos" (Marty y Reynaud).

4.5 PRUEBA DE LA COSTUMBRE.

La ley no necesita probarse: se invoca, pero no se prueba. En tal sentido, la ley tiene una fuerte ventaja de certeza. Por el contrario, la costumbre presenta problemas de prueba, pues para hacerla valer ante el juez, hay que demostrar su existencia, a menos que a éste le conste.

En materia civil no existen normas acerca de la prueba de la costumbre. Por eso, no hay restricciones para el uso de la prueba. Puede utilizarse cualquier medio de prueba: testigos, presunciones, escrituras, cualquier documento idóneo para que el juez se forme la convicción de que existe la costumbre invocada. Sin embargo, la costumbre puede estar tan generalizada que sólo baste invocarla por ser un hecho público y notorio. En tal caso le constará al juez y no necesitará ser probada, de acuerdo a un principio probatorio general.

El Código de Comercio, al tratar de la prueba de la costumbre en silencio de la ley, señala que la prueba de la costumbre sólo procede cuando no consta al juez. Si le consta se aplicará la costumbre sin necesidad de prueba. Pero, usualmente, será necesario probarla, en tanto al juez no le conste (art. 5 C. Com.).

El mismo Código señala para tal caso dos reglas básicas (Art. 4 C. Com.) para la prueba de la costumbre:

(1) por vía de dos sentencias judiciales que aseveran la existencia de la costumbre y se pronuncien conforme a ella; o,

(2) por medio de tres escrituras públicas en que las partes, al celebrar un acto jurídico, den por aceptada la costumbre, y que sean anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba.

4.6 LA CASACIÓN Y LA COSTUMBRE.

El recurso de casación en el fondo ha sido creado para anular sentencias dictadas con infracción de ley. El propósito que persigue es hacer efectivo el principio de supremacía de la ley en el sistema de fuentes del derecho. Mediante la casación se propende a preservar la uniformidad en la interpretación de la ley.

La infracción de una norma consuetudinaria queda, en principio, excluida de éste recurso. Sin embargo, indirectamente la Corte Suprema ha entrado a conocer de la costumbre a propósito de estos recursos, cuando se alega la infracción de alguna de esas normas que invocan o se remiten a la costumbre (por ejemplo, el art. 1546).

CAPÍTULO 5. LA JURISPRUDENCIA.

Las sentencias judiciales tienen un rol aparentemente reducido como fuentes del derecho chileno (art. 3 incº2 CC). Tal es uno de los postulados básicos de la tradición jurídica de la codificación. La sentencia vale como decisión judicial que resuelve un asunto particular, cuyo efecto vinculante se limita al caso particular.

Por otra parte, la jurisprudencia (entendida como doctrina emanada de las sentencias de los tribunales) lleva consigo la idea de generalidad, porque tiende a transformarse en una práctica, lo cual ha sido reforzado, como veremos más adelante, por las últimas reformas a nuestro sistema procesal.

5.1 ALCANCE DE LA SENTENCIA JUDICIAL

El Código Civil en sus primeros artículos precisa la extensión que corresponde a la ley, a la costumbre y a las resoluciones judiciales en el esquema de fuentes del derecho.

Art. 3 CC. Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.

Dos son las conclusiones que pueden extraerse de este artículo: la sentencia judicial produce sólo efectos relativos y, en consecuencia, la jurisprudencia no es fuente formal de normas generalmente obligatorias.

1. En primer lugar, **la sentencia sólo tiene fuerza obligatoria respecto del caso particular en que se dicta.** El juez establece simplemente una norma particular de conducta que no tiene otro alcance fuera de ese caso. El principio, en consecuencia, es el de los efectos relativos de la sentencia. Ni aún en caso que la propia Corte Suprema conozca de un asunto su decisión se extiende fuera de los límites de ese preciso negocio y por lo tanto no puede afectar a personas distintas de quienes han participado en el juicio, sea como partes, o como terceros.

Excepcionalmente la sentencia produce efectos erga omnes, es decir contra todos, quienesquiera que sean.

Ejemplos:

- Es el caso de la sentencia que resuelve en materia de legitimidad de un hijo (art. 315)
- y en general en cuestiones de estado civil,
- así como la que se pronuncia acerca de la calidad de heredero de una persona (art. 1264).

La fuerza obligatoria de la sentencia (restringida a las partes) se materializa en la institución de la cosa juzgada. En virtud de ella se producen dos efectos:

Acción de Cosa Juzgada: la fuerza obligatoria de la sentencia permite a quien ha obtenido en un juicio exigir que se cumpla lo resuelto, esto es, que se ejecute el fallo, incluso con el auxilio de la fuerza.

Excepción de Cosa Juzgada: a las partes que intervinieron en un juicio se les reconoce el derecho de impedir que se vuelva a ventilar ante la justicia el mismo asunto que ya ha sido objeto de un pronunciamiento.

Art. 174 CPC. Producen cosa juzgada las sentencias ejecutoriadas, esto es, aquellas en contra de las cuales no procede recurso alguno, sea porque se han interpuesto y han sido fallados, sea porque ya han vencido los plazos para hacerlo, sea porque simplemente el legislador los ha hecho improcedentes.

Límite subjetivo de la cosa juzgada: identidad de personas.

Límites objetivos: cosa pedida y causa de pedir.

La eficacia de la sentencia puede alcanzar a terceros que no son partes del litigio, no en razón de la cosa juzgada (falta la identidad de personas), sino porque la relación controvertida se conecta con situaciones jurídicas propias. Estos son los así llamados "efectos reflejos" de la sentencia.

Sin embargo, existen sentencias que son absolutas, que más allá de la cosa juzgada, afectan a todo el mundo. Hay que distinguir:

- Sentencias declarativas: se limitan a reconocer una situación de derecho creada anteriormente. A ellas se aplica la relatividad de la cosa juzgada. Excepcionalmente hay algunas que producen efectos generales.
- Sentencias constitutivas: crean una situación jurídica nueva. Producen efectos *erga omnes*, es decir, atañen a todo el mundo.

2. En segundo lugar, **la sentencia judicial no es fuente de normas generales.** En este punto difiere fundamentalmente el sistema romano continental con el del common law: en nuestra tradición jurídica el precedente no es suficiente para justificar un fallo. Las sentencias judiciales no pueden fundarse sólo en otra sentencia previa. Pueden hacerlo indirectamente, en la medida que se invoque en apoyo de una decisión fundada en la ley, la costumbre o un principio.

Precisando el alcance de este precepto (art. 3 inc. 2), la Corte Suprema ha declarado que "no tiene otro alcance que establecer, como principio general, el de que la sentencia dictada en una causa no puede ser invocada para resolver otros juicios en que se discute la misma cuestión o derecho, o en que el juez

tenga que aplicar el mismo precepto legal".

Aunque carezca de fuerza obligatoria general (lo que impide calificarla de fuente formal), la jurisprudencia constituye una importante fuente auxiliar, cuyo valor reside en su autoridad. Los argumentos basados en la autoridad invocan el prestigio de quien sostuvo una determinada opinión, el respeto que inspira. No se aduce un poder formalmente atribuido para resolver cierto tipo de casos, sino un poder derivado de la convicción o sugestión que produce su decisión.

La autoridad de la jurisprudencia no radica en la parte decisoria de la sentencia (*obiter dictum*) ni mucho menos en la expositiva, sino en el razonamiento que le sirve de fundamento, en los considerandos, aquello que en la tradición anglosajona se conoce como *ratio decidendi*.

Es propio de la autoridad que sirva para sostener un argumento. La jurisprudencia, por ello, apoya ciertas argumentaciones, desempeña un poderoso rol de convicción respecto de los propios jueces, tanto por la bondad intrínseca de los argumentos que comprende como por la especial estructura del sistema judicial chileno.

La jerarquía de los tribunales termina siendo un factor que potencia la influencia de las decisiones de los tribunales superiores, al ser ellos quienes controlan el correcto desempeño de los jueces inferiores. El recurso de casación en el fondo, que es de competencia exclusiva de la Corte Suprema, ha sido ideado para mantener una cierta uniformidad en la aplicación e interpretación del derecho, y por consiguiente su finalidad es discernir el derecho. Por su intermedio la Corte Suprema ejerce su función de control de la jurisprudencia y, necesariamente, expande la autoridad que emana de sus decisiones. El fortalecimiento de la casación (mediante la modificación de los requisitos para el recurso de queja, y la creación de salas especializadas en la Corte¹⁰) contribuyó a fortalecer esta función.

El carácter de mero argumento de autoridad de la jurisprudencia se muestra especialmente en la función de casación de la Corte Suprema: cuida de la observancia de la ley pero no está ligada por sus propios fallos. A diferencia de ello, el principio *del stare decisis* del common law vincula incluso al propio tribunal que dictó la decisión (aunque últimamente se advierte un aflojamiento del principio). En ello se muestra que en nuestro derecho la sentencia sólo produce un efecto relativo, y no general como en la tradición anglosajona.

Ahora, si bien hemos explicado que la jurisprudencia en Chile es una fuente auxiliar y no una fuente formal, es necesario acotar que dicha condición auxiliar ha tendido a matizarse por la incorporación de recursos judiciales que basan su

¹⁰ Dichas modificaciones legales fueron introducidas por la ley 19.374, la cual entró en vigor el año 1995.

procedencia en la existencia de sentencias contradictorias respecto a un mismo asunto. Así, por ejemplo, es el caso con el recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral (art. 483 del Código del Trabajo). También podemos mencionar el recurso de nulidad en materia procesal penal que, en caso de existir sentencias contradictorias, será conocido por la Corte Suprema. O el caso de la casación en el fondo que, frente a esta circunstancia, es conocido por el pleno de la Corte.

La existencia de estos recursos procesales no nos habilita para decir que la jurisprudencia muta su función y pasa a ser directamente una fuente formal del derecho, pero sí nos permite afirmar que su función de autoridad respecto a las fuentes del derecho se ha vuelto más fuerte.

CAPÍTULO 6. LA DOCTRINA.

6.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Todo pueblo que alcanza un grado de desenvolvimiento tiende a desarrollar la función social especializada de los expertos en derecho. El derecho, abandonando los estadios arcaicos de su desarrollo, pasa a ser demasiado complejo y sus funciones demasiado delicadas como para desentenderlas del trabajo científico.

Originalmente la tarea de los expertos se limitó simplemente a dar una opinión versada, sobre casos concretos. Así, por ejemplo, en la época del derecho romano preclásico y clásico los jurisconsultos jugaron un rol clave en el desarrollo del derecho, pues sus opiniones servían de base para fallar aquellos casos en que no resultaban directamente aplicables las reglas contenidas en las XII Tablas ni en los Edictos Pretorios¹¹. Con el correr del tiempo, esta función se extendió a la conceptualización y sistematización del derecho vigente.

Tras las codificaciones, se miró con recelo y se llegó incluso a prohibir los comentarios de las leyes. Ya Justiniano había hecho algo similar con su Digesto. La idea detrás de tal prohibición es que el derecho ya no puede ser concebido como algo que se desarrolla espontáneamente a partir de las opiniones de los jurisconsultos en relación a los casos nuevos que se van suscitando. El legislador se atribuye a para sí el papel de creador exclusivo del derecho, y se le da a la ley el status de fuente prioritaria del derecho.

Esta proscripción de los comentarios va más allá de la mera prohibición. En nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, se ordena que los casos dudosos sean informados al propio legislativo para que se dicten las leyes interpretativas que correspondan (art. 5 incº1 CC). Como fenómeno natural, a la codificación sigue un deterioro significativo de la doctrina.

Sólo en un período posterior, cuando surgen problemas de interpretación o vacíos y se hace necesario reordenar la exposición, la doctrina tiende a recuperar su lugar. Un ejemplo de esta renovada importancia la encontramos en el artículo 342 del Código Procesal Penal, que establece que la sentencia del juicio oral debe contener “las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias para fundar el fallo.” Sin embargo, el ejemplo citado es un caso excepcional, y no debe ser interpretado como evidencia de una regla general.

¹¹ Destacamos la figura de Ulpiano, quien fue el jurista romano más utilizado en la compilación de Justiniano. Además, sus tres máximas constituyen el sentido común de la justicia en prácticamente todas las tradiciones jurídicas occidentales: “Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a nadie, y dar a cada uno lo suyo”

6.2 VALOR NORMATIVO

La doctrina es hoy universalmente aceptada sólo como una fuente de autoridad: es antecedente para apoyar la interpretación de una norma, pero no puede fundamentar directamente una decisión.

La importancia de la doctrina como autoridad es variable, pues puede depender:

(a) Del valor que se le asigne a la ciencia en la respectiva tradición jurídica. En Alemania, por ejemplo, el Tribunal Supremo resuelve los casos difíciles con apego a la doctrina más destacada. Algo similar ocurre en Italia o en los estados escandinavos. En Inglaterra, por el contrario, el desarrollo del derecho ha sido tradicionalmente tarea de los propios jueces y no de una doctrina autónoma.

(b) De la consideración relativa del propio autor en el respectivo sistema, esto viene a ser determinado por la frecuencia con que los abogados o los jueces lo invocan en sus argumentaciones.

6.3 FUNCIONES DE LA DOCTRINA EN RELACIÓN CON EL DERECHO VIGENTE.

1. En la comprensión y precisión conceptual del derecho.
2. En el desarrollo del derecho.
3. En la consolidación del derecho.
4. En el control de las decisiones.

ANEXO: CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO

Las fuentes del derecho, su formulación, conceptualización y clasificación son una materia cuya regulación legal, contenida en el título preliminar, es más bien escueta. Por esa razón, buena parte del desarrollo en torno a las fuentes del derecho es doctrinaria y, como tal, resulta discutible. La idea de este anexo es aclarar ese panorama doctrinario.

Las fuentes del derecho son, en términos generales, toda constancia verbal o escrita que permita captar la existencia de normas jurídicas. Respecto a la existencia de las normas jurídicas, debemos plantearnos dos preguntas relacionadas pero distintas: a) ¿Por qué surge tal o cual norma jurídica?; b) ¿De qué forma surge tal o cual norma jurídica?

La primera pregunta nos remite al concepto de fuente material del derecho: todos los factores que explican el nacimiento y determinan el contenido del derecho. Las fuentes materiales se refieren a hechos de la vida social y, como tales, pueden ser hechos políticos, económicos, culturales, religiosos, etc.

La segunda pregunta nos remite al concepto de fuente formal del derecho: la forma en que se expresan las normas jurídicas. Históricamente hablando, antes del surgimiento del derecho moderno, la primera fuente formal es la costumbre que surge espontáneamente en los pueblos primitivos. La jurisprudencia emerge del desarrollo de organismos especializados llamados tribunales. La ley como fuente formal, caracterizada como una decisión con carácter general y obligatoria, solo emerge con los Estados Modernos.

Lo que define al sistema jurídico es su sistema de fuentes. En la tradición del Common Law, cuyo sistema jurídico tiene una fuerte base en el precedente, la jurisprudencia tiene un rol privilegiado dentro de las fuentes formales del derecho, toda vez que las decisiones de un tribunal son generalmente obligatorias para los demás. En la tradición romanista, en cambio, la fuente formal más importante es la ley (art. 1 CC), y la jurisprudencia solo tiene un rol subordinado, pues carece de un contenido generalmente obligatorio (art. 3 CC).

Las fuentes formales del derecho admiten varias clasificaciones:

i) Según la forma en que se crean, pueden ser *fuentes originadas en una decisión*, como la ley, o *fuentes de origen espontáneo*, como la costumbre.

En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la ley como la costumbre son consideradas fuentes formales del derecho, según lo establecen los artículos 1 y 2 del CC.

ii) Según su ámbito de aplicación, pueden ser *fuentes de normas generales*, como la ley o la costumbre, o *fuentes de normas de aplicación particular*, como la jurisprudencia.

En nuestro ordenamiento jurídico, inserto en la tradición romanista, y a diferencia del Common Law, solo la ley y la costumbre son fuente de normas generalmente obligatorias. Según el tenor literal del art. 3 incº2 CC, la jurisprudencia solo tiene fuerza obligatoria para el caso en que se dicta.

iii) Según si pueden servir como fundamento a una decisión judicial, pueden ser *fuentes directas*, como la ley o la costumbre, o *fuentes indirectas*, como la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia pueden servir para interpretar o para sistematizar la legislación vigente, pero no puede ser el único sustento de una sentencia judicial. En la terminología clásica, podría decirse que las fuentes indirectas son aquellas cuya fuerza deriva del hecho de que tienen autoridad (*auctoritas*), pues no tienen potestad (*potestas*).

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley y la costumbre son fuentes formales directas, toda vez que pueden servir de base para fundamentar la sentencia judicial. La jurisprudencia y la doctrina serían fuentes formales indirectas.

A modo de síntesis y conclusión, podemos decir que las fuentes formales del derecho son la ley y la costumbre. La jurisprudencia y la doctrina pueden ser consideradas fuentes formales indirectas, si es que reconocemos esta última clasificación. Pero no es preciso decir que la jurisprudencia y la doctrina son fuentes materiales, sino solo en la medida en que, de hecho, sirvan como fuente de inspiración para la dictación de una norma jurídica nueva.